



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.010573/2019-99 (RJ2020/01228).

Data do julgamento: 21/12/2021

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Acusado: Thompson de Oliveira Schemes

Ementa: Responsabilidade pela (i) prática de churning, em infração à Instrução CVM nº 08/1979, inciso I c/c inciso II, alínea "c"; e (ii) utilização de senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo de cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico, em infração à Instrução CVM nº 497/2011, art. 13, inciso VII. Absoluções.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:

1) Por **unanimidade** de votos: pela **absolvição** de **Thompson de Oliveira Schemes** da acusação de utilização de senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo de cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico, em infração ao art. 13, VII, da Instrução CVM nº 497/11.

2) **Por maioria** de votos: pela **absolvição** de **Thompson de Oliveira Schemes** da acusação de prática de *churning* – operação fraudulenta no mercado de capitais, em infração ao inciso I, c/c o inciso II, 'c', da Instrução CVM 08/79.

A Diretora Flávia Perlingeiro divergiu do voto do Diretor Relator, por entender que a prova indiciária presente nos autos era suficiente para comprovar a materialidade e autoria da prática de *churning*. Após expor sobre o assunto, votou pela:

- Condenação de Thompson de Oliveira Schemes à multa de R\$ 250.000,00, pela prática de *churning* – operação fraudulenta no mercado de capitais, em infração ao inciso I, c/c o inciso II, 'c', da Instrução CVM nº 08/79.

- Absolvição de Thompson de Oliveira Schemes da acusação de utilização de senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo de cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico, em infração ao art. 13, VII, da Instrução nº CVM 497/11.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, dispensando-se a videoconferência, na forma da Resolução CVM nº 45/21.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Perlingeiro, Fernando Galdi e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 27/01/2022, às 18:18, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 28/01/2022, às 11:19, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 28/01/2022, às 17:01, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Caio Galdi, Usuário Externo**, em 31/01/2022, às 15:31, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1431857** e o código CRC **30F818EF**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1431857** and the "Código CRC" **30F818EF**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2020/1228

(Processo Eletrônico nº SEI 19957.010573/2019-99)

Reg. Col. nº 2183/21

Acusado: Thompson de Oliveira Schemes

Assunto: Apurar eventual responsabilidade pela (i) prática de *churning*, em infração à Instrução CVM nº 08/1979, inciso I c/c inciso II, alínea “c”; e (ii) utilização de senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo de cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico, em infração à Instrução CVM nº 497/2011, art. 13, inciso VII

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Relatório

I. Objeto e Origem

1. Trata-se de processo administrativo sancionador (“Processo”) instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Área Técnica”) para apurar a responsabilidade de Thompson de Oliveira Schemes (“Thompson Schemes” ou “Acusado”) pela suposta prática, no período de julho de 2012 a janeiro de 2013, das seguintes irregularidades: (i) *churning*, em infração à Instrução CVM nº 08/1979, inciso I c/c inciso II, alínea “c”¹; e (ii) utilização de senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo de cliente para

¹ “I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico, em infração à então vigente Instrução CVM nº 497/2011, art. 13, inciso VII².

2. O Processo originou-se do Processo Administrativo CVM nº 19957.004160/2019-75 (“Processo Originário”)³, que tratou de reclamação (“Reclamação”)⁴ apresentada à Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (“SOI”) em 06.07.2016 por B.R.S. (“Reclamante”), filha e única herdeira da investidora K.M.S.. A Reclamação referiu-se à atuação de (i) sociedade corretora de títulos e valores mobiliários (“Intermediária”) junto à qual a mãe da Reclamante, a investidora K.M.S., manteve conta até o respectivo falecimento, em 27.01.2013; e (ii) Thompson Schemes, agente autônomo de investimento responsável pelo atendimento da investidora K.M.S. no âmbito da Intermediária.

3. Em síntese, a Reclamação aponta que a Intermediária e Thompson Schemes teriam realizado, nos meses que antecederam o falecimento da investidora K.M.S., sucessivas operações de compra e venda de valores mobiliários não autorizadas por tal investidora, mediante a utilização de senha de seu uso exclusivo. Tais operações teriam causado elevado prejuízo a K.M.S. e evidenciariam a violação de múltiplos dispositivos regulamentares aplicáveis à atuação dos referidos participantes de mercado, em especial a prática das infrações objeto do presente Processo.

II. Processo Originário

4. Em termos objetivos, a Reclamação apresenta a seguinte narrativa quanto aos fatos objeto deste Processo:

(i) a investidora K.M.S. se tornou cliente da Intermediária em junho de 2012⁵, quando transferiu, à custódia da referida instituição, a carteira de ações de sua propriedade⁶;

² “Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2º: (...) VII - usar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico;” A Instrução CVM nº 497/2011 foi revogada pela Resolução CVM nº 16/2021. O art. 18, inciso VII, da nova resolução tem redação idêntica à do referido art. 13, inciso VII, da instrução revogada.

³ Doc. SEI 0725647.

⁴ Doc. SEI 0725647 (fls. 2-9).

⁵ A ficha cadastral da investidora K.M.S. junto à Intermediária encontra-se datada de 29.05.2012 (Doc. SEI 0725647, fls. 149-150).

⁶ Figurou como anexo à Reclamação documento endereçado à investidora K.M.S. intitulado “*Confirmação de Movimentação de Ativos*”, expedido em papel timbrado da então denominada BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, que informa a transferência, em 25.06.12, de carteira de ações de propriedade da investidora K.M.S. para a custódia da Intermediária, na Central Depositária BM&FBOVESPA (Doc. SEI 0725647, fl. 20).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

- (ii) Thompson Schemes seria o agente autônomo de investimento responsável pelo atendimento da investidora K.M.S. junto à Intermediária⁷;
- (iii) a senha de acesso da investidora K.M.S. ao sistema de *home broker* da Intermediária seria do conhecimento do Acusado, conforme correio eletrônico juntado aos autos⁸;
- (iv) a partir de julho de 2012, quando a investidora K.M.S. já se encontrava “*gravemente adoentada*”, sucessivas operações de compra e venda de valores mobiliários teriam sido realizadas⁹ sem sua autorização, o que haveria lhe causado prejuízo financeiro considerável¹⁰, inclusive a título de multas¹¹, e gerado, em contrapartida, “*retorno desproporcional e incomum em taxa de corretagem*” para a Intermediária;
- (v) em outubro de 2012, com o avanço de sua enfermidade, a investidora K.M.S. teria ficado inconsciente no leito hospitalar, sem qualquer condição de determinar operações em sua conta de custódia¹², havendo falecido em 27.01.2013¹³;

⁷ Consta dos autos ficha cadastral de Thompson Schemes junto à CVM, a qual indica o respectivo credenciamento como agente autônomo de investimento em 23.09.2009 (Doc. SEI 0725647, fls. 124-125).

⁸ Trata-se de mensagem supostamente enviada por Thompson Schemes à investidora K.M.S., mediante a qual o Acusado informa que (i) havia criado conta de e-mail para a investidora K.M.S., bem como lhe fornece os pertinentes endereço de e-mail e senha de acesso; e (ii) ao entrar na recém-criada conta de e-mail, a investidora K.M.S. veria um correio eletrônico enviado pela Intermediária, contendo seu *login* e senha de acesso (Doc. SEI 0725647, fl. 22). Registre-se que não consta da mensagem em questão qualquer cabeçalho indicativo da data e horário do respectivo envio ou ainda dos nomes e endereços de correio eletrônico dos respectivos remetente e destinatário.

⁹ Notas de corretagem das operações realizadas a partir da conta da investidora K.M.S. junto à Intermediária (Doc. SEI 0725647, fls. 28 a 97) revelam, no que diz respeito ao período de suposto cometimento das infrações objeto deste processo (julho de 2012 a janeiro de 2013), que (i) houve poucas negociações, em 3 pregões apenas, de 02.07.2012 a 12.07.2012; (ii) não houve negociações entre 13.07.2012 e 30.08.2012; (iii) houve muitos negócios, em 30 pregões, entre 31.08.2012 e 01.11.2012; e (iv) mais uma vez, houve poucas negociações, em 7 pregões, de 02.11.2012 a 27.01.2013.

¹⁰ O valor total do prejuízo gerado não é apontado na Reclamação, embora se possa extrair da petição inicial de ação de indenização juntada aos autos, movida pela Reclamante em face da Intermediária, que (i) o valor total da carteira de ações transferida à custódia da Intermediária corresponderia a R\$ 114.693,00 na data da transferência da custódia (25.06.2012) e, segundo a Reclamante, teria sido integralmente dilapidado pela atuação do Acusado; e (ii) atualizado até a data da referida petição inicial (29.08.2016), tal valor montaria a R\$ 228.572,77 (Doc. SEI 0725647, fls. 193, 203 e 207). Relevante também anotar que, conforme revelam extratos da conta da investidora K.M.S. junto à Intermediária anexados à Reclamação, relativos ao período de junho de 2012 a novembro de 2014 (Doc. SEI 0725647, fls. 99 a 110), o saldo em conta da investidora K.M.S. passou a ser quase que permanentemente negativo, de 05.11.2012 até a data do seu falecimento (27.01.2013).

¹¹ Extratos da conta da investidora K.M.S. junto à Intermediária anexados à Reclamação, relativos ao período de junho de 2012 a novembro de 2014 (Doc. SEI 0725647, fls. 99 a 110), demonstram que foram aplicadas à investidora em questão diversas multas referentes a saldo negativo em conta e a operações realizadas em bolsa no período do suposto cometimento das infrações objeto deste Processo (junho de 2012 a janeiro de 2013). Conforme cálculo da Reclamante extraído da petição inicial da supracitada ação de indenização que esta moveu em face da Intermediária, o valor das multas aplicadas à Intermediária totalizaria R\$ 10.423,44 (Doc. SEI 0725647, fl. 195).

¹² Não foram juntados aos autos quaisquer documentos que comprovem o suposto período de hospitalização da investidora K.M.S. ou quaisquer informações relativas ao seu real estado de saúde e respectiva evolução.

¹³ Conforme Escritura de Inventário e Adjudicação de Bens do Espólio da investidora K.M.S. lavrada em 26.12.2013 e anexada à Reclamação, a investidora K.M.S. “*faleceu em 27/01/2013 na cidade do Rio de Janeiro*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

- (vi) a Reclamante haveria obtido da Intermediária supostas transcrições de ordens de compra e venda de valores mobiliários transmitidas pela investidora K.M.S. ao Acusado via aplicativo de mensagens desenvolvido pela Intermediária, referentes aos meses de julho, novembro e dezembro de 2012¹⁴, não tendo sido possível obter as transcrições relativas aos demais meses;
 - (vii) durante o período em que as operações não autorizadas de compra e venda de valores mobiliários ocorreram, a investidora K.M.S., além de hospitalizada, teria 61 anos de idade e não deteria os conhecimentos técnicos necessários para se utilizar de *e-mails* e do aplicativo da Intermediária para autorizar operações de compra e venda de valores mobiliários; e
 - (viii) nos termos das transcrições obtidas pela Reclamante¹⁵, sua mãe haveria usado “*jargões técnicos*” e “*expressões tipicamente de operadores de mercado, com as quais não tinha qualquer contato, tais como ‘zera no leilão’, ‘compra a mercado’, ‘vende 13k a 2,36’, dentre outras, demonstrando a fraude cristalina perpetrada para dilapidar seu patrimônio e gerar corretagem*”.
5. O Acusado não respondeu aos questionamentos formulados pela SOI quanto ao conteúdo da Reclamação. A Intermediária, a seu turno, alegou, em manifestação de 13.09.2016¹⁶, que:
- (i) além de agente autônomo de investimento contratado pela Intermediária, Thompson Schemes também seria primo irmão da Reclamante e sobrinho “*próximo*” da investidora K.M.S., fato que haveria sido “*propositalmente (e convenientemente) omitido na presente reclamação*” e que justificaria a confiança nele depositada pela investidora K.M.S.;
 - (ii) todas as movimentações realizadas na carteira de ações da investidora K.M.S. teriam contado com sua anuência, embora não houvesse sido possível auditar 100% das ordens por ela transmitidas, o que se explicaria, segundo a Intermediária, em razão de muitas das ordens terem sido realizadas presencialmente, sem qualquer registro formal, devido à relação familiar existente entre os envolvidos;

aos 61 (sessenta e um) anos conforme certidão de óbito expedida pelo 5º RCPN do Rio de Janeiro (...)” (Doc. SEI 0725647, fl. 11).

¹⁴ Doc. SEI 0725647 (fls. 24-26).

¹⁵ Doc. SEI 0725647 (fls. 24-26).

¹⁶ Doc. SEI 0725647 (fls. 118-119).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

- (iii) as transcrições, juntadas aos autos pela Reclamante, das interações mantidas entre a investidora K.M.S. e o Acusado no aplicativo de mensagens desenvolvido pela Intermediária comprovariam que houve nítida interação entre os dois e que, durante alguns dos meses a que se refere a Reclamação, haveria registro formal das autorizações da investidora K.M.S. quanto aos negócios realizados;
- (iv) diferentemente do alegado pela Reclamante, a investidora K.M.S. contaria com anos de relacionamento com o sistema financeiro, o que restaria evidenciado pelo fato de haver transferido à custódia da Intermediária uma carteira de ações “*nada conservadora*”;
- (v) o conteúdo da Reclamação refletiria, em verdade, suposto inconformismo da Reclamante quanto à queda abrupta do valor das ações que compuseram o portfólio de investimentos de sua falecida mãe e fariam parte de sua herança; e
- (vi) dito inconformismo haveria motivado o questionamento da validade de manifestações regulares de vontade externadas pela investidora K.M.S., a formulação da Reclamação e o ajuizamento de ação judicial de indenização por danos materiais e morais em face da Intermediária (“Ação Indenizatória”)¹⁷.

6. Atendendo a novo pedido de informações formulado pela SOI, a Intermediária forneceu, em 14.10.2016, dentre outros, os seguintes documentos e esclarecimentos adicionais¹⁸⁻¹⁹: (i) ficha cadastral completa da investidora K.M.S. e documentos correlatos²⁰; (ii) histórico das ordens de compra e venda de valores mobiliários vinculadas à conta mantida pela investidora K.M.S. junto à Intermediária até a data do seu falecimento (27.01.2013)²¹; e (iii) informação de que as ordens de compra e venda de valores mobiliários da investidora K.M.S. não teriam sido transmitidas via *home broker*, mas por telefone (não gravado); presencialmente; e por meio do *chat* de mensagens do aplicativo desenvolvido pela Intermediária.

7. A respeito das manifestações da Intermediária, a Reclamante destacou, em linhas gerais, em 25.10.2016²², que (i) a Intermediária haveria confessado não ter registro formal de parte das ordens emitidas pela investidora K.M.S., o que representaria uma infração autônoma, não sendo

¹⁷ A Ação Indenizatória, autuada sob o número 027823-59.2016.8.19.0001, tramitou perante 33ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. A respectiva petição inicial consta do Doc. SEI 0725647 (fls. 192-208).

¹⁸ A manifestação da Intermediária de 14.10.2016 consta do Doc. SEI 0725647 (fls. 145-146).

¹⁹ A Intermediária não forneceu a análise do perfil da investidora K.M.S. pois, alegadamente, tal perfil não teria sido preenchido (Doc. SEI 0725647, fls. 145).

²⁰ Doc. SEI 0725647 (fls. 149-154).

²¹ Doc. SEI 0725647 (fls. 155-164).

²² Doc. SEI 0725647 (fls. 169-170 e 176-178).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

os laços de parentesco existentes entre investidora e Acusado justificativa hábil a elidir a aplicação de norma cogente que determina à Intermediária o registro e conservação das referidas ordens; e **(ii)** as ordens apresentadas pela Intermediária seriam falsas, como supostamente apontado na Reclamação.

8. Em 20.12.2016, ouvida quanto a esta última manifestação da Reclamante, a Intermediária reiterou os termos de suas manifestações anteriores²³.

9. No dia 13.01.2017, a SOI remeteu, para providências cabíveis, o Processo Originário à SMI²⁴, que, em 06.10.2017, enviou ofícios à Intermediária e ao Acusado solicitando as respectivas manifestações prévias²⁵. Mediante tais ofícios, Intermediária e Acusado foram questionados a respeito dos fatos em apuração no Processo Originário, com destaque **(i)** quanto ao Acusado, para a suposta utilização de senha de uso exclusivo da investidora K.M.S.; e **(ii)** quanto à Intermediária, para a alegada ausência de gravação das ordens transmitidas pela investidora em questão, em aparente violação ao art. 12, parágrafo único; e art. 13, ambos da Instrução CVM nº 505/2011²⁶.

10. O Acusado não respondeu aos questionamentos referidos no parágrafo anterior. A seu turno, a Intermediária sustentou, em manifestação de 17.10.2017²⁷, que:

- (i)** ao tomar contato com o conteúdo da Reclamação, iniciou procedimento interno de auditoria de ordens, para identificar a integralidade dos registros das operações executadas em nome da investidora K.M.S.;
- (ii)** no curso da referida auditoria, Thompson Schemes apresentou a maioria das autorizações prévias outorgadas pela investidora K.M.S. para execução de ordens, não tendo sido possível, contudo, localizar parte das autorizações prévias;

²³ Doc. SEI 0725647 (fl. 181).

²⁴ Doc. SEI 0725647 (fls. 183-184).

²⁵ Doc. SEI 0725647 (fls. 209-212).

²⁶ “Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: I – escrito; II – telefone e outros sistemas de transmissão de voz; ou III – sistemas eletrônicos de conexões automatizadas. Parágrafo único. Todas as ordens devem ser registradas, identificando-se o horário do seu recebimento, o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua execução. Art. 13. O intermediário deve arquivar os registros das ordens transmitidas pelos clientes e as condições em que foram executadas, independentemente de sua forma de transmissão.”

²⁷ A manifestação prévia da Intermediária consta exclusivamente dos autos do Processo Originário, não tendo sido reproduzida nos autos deste Processo (Doc. SEI 0725914).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

- (iii) na auditoria em questão, a Intermediária também identificou possível compartilhamento de senhas entre o Acusado e a investidora K.M.S., com base em correio eletrônico trocado entre eles²⁸;
 - (iv) as evidências “ii” e “iii” deste parágrafo representariam violações a políticas internas e regras de conduta da Intermediária, que teriam motivado o encerramento de seu relacionamento com Thompson Schemes;
 - (v) os fatos objeto do Processo Originário também estariam sendo discutidos em ação de indenização ajuizada pela Reclamante em face da Intermediária perante a 33ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (“Ação Indenizatória”) ²⁹⁻³⁰;
 - (vi) a Intermediária haveria proposto uma composição amigável da Ação Indenizatória, o que não foi aceito pela Reclamante;
 - (vii) nada obstante, a Intermediária teria convicção de que a investidora K.M.S. tinha ciência das operações, tanto que sua filha, a Reclamante, optou por “*não tomar qualquer medida contra seu parente (Sr. Thompson)*”³¹; e
 - (viii) a respeito da aparente violação ao art. 12, parágrafo único; e art. 13 da Instrução CVM nº 505/2011, a Intermediária defendeu que (a) a atuação de Thompson Schemes se tratou de episódio pontual e isolado, motivado pela relação de confiança mantida com sua tia, a investidora K.M.S.; (b) ao identificar a falha, a Intermediária prontamente encerrou seu relacionamento com o Acusado; (c) à luz de tais fatos, não haveria materialidade ou justa causa para a instauração de processo administrativo sancionador em face da Intermediária.
11. Concluída a fase investigativa do Processo Originário, a SMI (i) encaminhou, em 10.12.2019, ofício de alerta à Intermediária³², para que o disposto na Instrução CVM nº

²⁸ A Intermediária apresenta em anexo à manifestação prévia, como documento supostamente comprobatório do compartilhamento de senha em questão (Doc. SEI 0725914, fl. 41), o mesmo correio eletrônico que, segundo a Reclamação, comprovaria o mesmo compartilhamento (Doc. SEI 0725647, fl. 22). Trata-se, como anteriormente afirmado, de mensagem supostamente enviada pelo Acusado à investidora K.M.S. informando-lhe que havia criado conta de e-mail para a investidora K.M.S. e que, ao entrar na referida conta, a investidora veria um e-mail da Intermediária, contendo seu *login* e senha de acesso.

²⁹ Processo nº 027823-59.2016.8.19.0001.

³⁰ Por meio de sua manifestação prévia, a Intermediária juntou aos autos do Processo Originário a contestação que apresentou no âmbito da Ação Indenizatória (Doc. SEI 0725914, fls. 23-40).

³¹ Nesse ponto, a manifestação prévia parece fazer referência ao fato de que o Acusado não figura como réu da Ação Indenizatória, que foi ajuizada exclusivamente em face da Intermediária.

³² Trata-se do Ofício de Alerta nº 64/2019/CVM/SMI, constante exclusivamente dos autos do Processo Originário (Doc. SEI 0897535).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

505/2011 fosse plenamente observado; e (ii) lavrou, em 24.01.2020, termo de acusação em face de Thompson Schemes (“Acusação”)³³.

III. Acusação

12. Entendendo estar de posse de elementos suficientes de autoria e materialidade, a SMI imputou a Thompson Schemes a prática, no período de julho de 2012 a janeiro de 2013, das seguintes irregularidades: (i) *churning*, em violação à Instrução CVM nº 08/1979, inciso I c/c inciso II, alínea “c”; e (ii) utilização de senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico, em violação à então vigente Instrução CVM nº 497/2011, art. 13, inciso VII.

13. Para a caracterização das irregularidades em questão, a SMI levou em consideração, em especial, os seguintes elementos constantes dos autos³⁴:

- (i) e-mail supostamente comprobatório de que o *login* e a senha de acesso da investidora K.M.S. à sua conta na Intermediária seriam de conhecimento do Acusado, o que significaria, nas palavras da Acusação, que *“Thompson estava de posse do login e da senha da investidora na [Intermediária] e, segundo sua vontade, poderia acessar a corretora em nome da investidora e transmitir ordens para a negociação de valores mobiliários”* e justificaria *“a desconfiança da denunciante sobre uma possível fraude em relação às mensagens trocadas com Thompson”*;
- (ii) a ausência de registro de autorização da investidora K.M.S. em relação às ordens de compra e venda de valores mobiliários executadas pelo Acusado em setembro e outubro de 2012, meses em que o número de negócios realizados a partir da conta da investidora em questão foi consideravelmente superior se comparado com os demais meses do período de suposto cometimento das infrações (julho, agosto, novembro e dezembro de 2012 e janeiro de 2013);
- (iii) as alegações contidas na Reclamação a respeito do estado de saúde da investidora K.M.S. no aludido período, segundo as quais dita investidora teria sido acometida por grave enfermidade, teria estado hospitalizada e em situação extremamente vulnerável; e

³³ Doc. SEI 0883611.

³⁴ Conforme se extrai, em especial, da seção IV da Acusação (Doc. SEI 0883611, fls. 4-5).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

- (iv) cálculos efetuados pela BSM Supervisão de Mercados (“BSM”) a partir das operações de compra e venda de valores mobiliários realizadas em nome da investidora K.M.S. no período de julho de 2012 a janeiro de 2013, os quais revelariam que os dois parâmetros-limite usualmente utilizados para a caracterização da prática de *churning* no Brasil³⁵ — *turnover ratio* anualizada acima de 8 vezes³⁶ e *cost/equity ratio* anualizada acima de 21%³⁷ — teriam sido ultrapassados no caso concreto, no qual se verificou uma *turnover ratio* anualizada de 62,53 vezes e um *cost/equity ratio*, também anualizada, de 49,19%³⁸.

³⁵ Os parâmetros-limite em questão, nos quais se baseia a Acusação, foram extraídos de estudo da BSM contido em seu Relatório de Análise nº 01/2011, confeccionado em julho de 2011 com o intuito de sugerir parâmetros para a caracterização da prática de *churning* no Brasil, a serem adotados na atividade de *enforcement*, da BSM. Como se extrai do sumário executivo do estudo em questão: “Ao longo dos últimos anos, a BSM tem se deparado, no decorrer de suas atividades de supervisão e acompanhamento dos mercados administrados pela BM&FBOVESPA, com inúmeras irregularidades na gestão do patrimônio dos investidores. Frequentemente, estas irregularidades são agravadas pela realização de sucessivas operações com o objetivo preponderante de gerar maiores receitas (taxas de corretagem e comissões). Em diversas jurisdições, essa prática de efetuar negócios de maneira excessiva com o objetivo de gerar maiores receitas, denominada *churning* ou *overtrading*, está bem caracterizada nas normas, inclusive com indicadores precisos para apontar se o volume de negócios e de receitas gerados são indicativos da prática de *churning*. No Brasil, essa prática pode ser tipificada como quebra do dever de lealdade em razão da atuação contrária ao melhor interesse do investidor (infração ao artigo 4º, parágrafo único, da Instrução Normativa CVM nº 387/03) e como operação fraudulenta nos termos dos itens I e II, alínea “c” da Instrução Normativa CVM nº 8/79. Contudo, as análises efetuadas até então carecem de indicadores objetivos por meio dos quais se possa afirmar que houve negociação excessiva e geração de receitas acima de níveis aceitáveis. Neste trabalho, sugerem-se dois indicadores para subsidiar as análises e decisões da BSM quanto à caracterização da prática do *churning*. A exemplo do que ocorre em outras jurisdições, é proposta a utilização de um indicador para averiguar se o volume de negócios foi excessivo e de outro para aferir se o total de despesas incorridas pelo investidor foi demasiado. (...) Estes indicadores serão formalmente adotados para analisar casos em que se perceba indícios da prática de *churning* e auxiliarão as decisões tomadas no âmbito da atividade de *enforcement* da BSM.” (grifos meus). (Doc. SEI 0819882, fls. i-ii).

³⁶ Nos termos do referido Relatório de Análise nº 01/2011 da BSM: “O primeiro indicador, conhecido como Turnover Ratio, indica o número de ‘giros’ efetuados com a carteira do cliente, comparando-se o patrimônio médio do cliente com o volume total de compras efetuado. Como benchmark para verificar se determinada Turnover Ratio é excessiva, sugere-se compará-la com a taxa de turnover dos fundos de investimento em ações, partindo-se do princípio de que é razoável supor que um investidor particular gire sua carteira a taxa inferior à de fundos geridos por profissionais. De acordo com os cálculos efetuados, taxas de turnover superiores a 8 seriam fortemente indicativas da prática de *churning*, não podendo-se descartar, contudo, a possibilidade de *churning* para taxas entre 2 e 8.” (grifos meus). (Doc. SEI 0819882, fls. i-ii).

³⁷ Conforme também se extrai do supracitado Relatório de Análise nº 01/2011 da BSM: “Para verificar a presença de uma excessiva despesa para os investidores, sugere-se a adoção do indicador denominado Cost-Equity Ratio, que compara o total de despesas que incidiu sobre a carteira do investidor com seu patrimônio médio. Este indicador reflete o retorno mínimo que seria necessário para cobrir as despesas que incidiram sobre a carteira do investidor em determinado período. Como base de comparação para verificar se determinada cost-equity ratio é elevada ou não, sugere-se compará-la com a rentabilidade histórica do Ibovespa, que, nos últimos 15 anos, foi de, aproximadamente, 21% ao ano. Ou seja, cost-equity ratios superiores a 21% ao ano seriam consideradas como indicativas da prática de *churning*, vez que reduziriam a probabilidade do investidor obter algum lucro a menos de 50%.” (grifos meus). (Doc. SEI 0819882, fls. ii).

³⁸ Os cálculos em questão foram encaminhados por Ofício da BSM de 11.10.2019 (Doc. SEI 0859965) e constam de planilha que integra os presentes autos (Doc. SEI 0859966).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

14. Nessa ordem de raciocínio, sustenta a SMI estarem presentes, *in casu*, os três requisitos caracterizadores da prática do *churning*³⁹, a saber:

- (i) controle sobre as operações cursadas em nome do investidor: ponto demonstrado em razão da atuação do Acusado como agente autônomo de investimento que atendia à investidora K.M.S. e com base nos elementos “i” a “iii” do parágrafo anterior;
- (ii) giro excessivo da carteira de investimentos à luz do perfil do cliente: ponto evidenciado a partir dos cálculos efetuados pela BSM indicados no item “iv” do parágrafo anterior, destacando-se, em relação ao perfil da investidora K.M.S., que se tratava de pessoa idosa e hospitalizada, situação incompatível com o giro observado em sua carteira; e
- (iii) intenção de gerar receitas de corretagem ou outras comissões: segundo a tese acusatória, seria nítida a alteração no perfil das operações cursadas nos momentos que antecederam o falecimento da investidora K.M.S., o que demonstraria a intenção do Acusado de gerar taxas, *“aproveitando-se da incapacidade de supervisão da investidora naquele período”*⁴⁰.

15. Adicionalmente, afirma a SMI ser *“possível concluir com razoável certeza que, ao menos no período em que a investidora esteve hospitalizada, quando houve negociações quase diárias em nome dela, Thompson utilizou a senha de sua cliente para a transmissão de ordens, desrespeitando o art. 13, VII, da Instrução CVM nº 497 (...)”*⁴¹.

IV. Manifestação da Procuradoria Federal Especializada

16. Em 17.02.2020, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) proferiu parecer⁴², manifestando entendimento de que a Acusação observou os requisitos constantes dos arts. 5º e 6º da então vigente Instrução CVM nº 607/2019⁴³, à exceção daquele previsto no inciso VII do art. 6º c/c inciso I do art. 13⁴⁴.

³⁹ A respeito do *churning*, a SMI juntou aos presentes autos: (i) o supracitado Relatório de Análise nº 01/2011, confeccionado pela BSM (Doc. SEI 0819882); (ii) um estudo sobre indicadores de *churning* no Brasil, desenvolvido pela CVM em junho de 2013 (Doc. SEI 0819946); e (iii) uma palestra proferida pelo ex-Diretor da CVM Gustavo Gonzalez em março de 2019 sobre o tema (Doc. SEI 0819949).

⁴⁰ Doc. SEI 0883611 (fl. 4).

⁴¹ Doc. SEI 0883611 (fl. 5).

⁴² Doc. SEI 0945291.

⁴³ A Instrução CVM nº 607/2019 foi revogada pela Resolução CVM nº 45/2021, a qual entrou em vigor em 01.10.2021 e foi editada no bojo do processo de revisão e consolidação normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto nº 10.139/2019.

⁴⁴ “Art. 6º Nas hipóteses em que a superintendência considerar que dispõe de elementos conclusivos quanto à autoria e à materialidade da irregularidade constatada, deverá ser lavrado termo de acusação do qual constará: (...) VII – proposta de comunicação a que se refere o art. 13, se for o caso. (...) Art. 13. Compete à Superintendência



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

17. A esse respeito, ressaltou a pertinência de comunicação ao Ministério Público, haja vista a presença de indícios da prática dos crimes previstos no art. 27-E da Lei nº 6.385/1976⁴⁵ e no art. 171 do Código Penal⁴⁶. A comunicação em questão foi efetivada em 12.03.2020⁴⁷.

V. Defesa

18. Devidamente citado, o Acusado não apresentou razões de defesa⁴⁸.

VI. Distribuição do Processo

19. Na reunião do Colegiado de 25.05.2021, o Processo foi distribuído para minha relatoria⁴⁹.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2021.

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

Geral efetuar comunicações: I – ao Ministério Público, quando verificada a existência de indícios de crimes definidos em lei como de ação pública;”

⁴⁵ “Art. 27-E. Exercer, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, a atividade de administrador de carteira, agente autônomo de investimento, auditor independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou qualquer outro cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado na autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento: Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”

⁴⁶ “Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.”

⁴⁷ Docs. SEI 0953821 e 0956130.

⁴⁸ Docs. SEI 0948769, 1181924, 1178334, 1182021 e 1266149.

⁴⁹ Doc. SEI 1270953.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2020/1228

(Processo Eletrônico nº SEI 19957.010573/2019-99)

Reg. Col. nº 2183/21

Acusado: Thompson de Oliveira Schemes

Assunto: Apurar eventual responsabilidade pela **(i)** prática de *churning*, em infração à Instrução CVM nº 08/1979, inciso I c/c inciso II, alínea “c”; e **(ii)** utilização de senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo de cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico, em infração à Instrução CVM nº 497/2011, art. 13, inciso VII

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I. Introdução

1. Trata-se de Processo¹ instaurado pela SMI para apurar a responsabilidade de Thompson Schemes pela suposta prática das seguintes irregularidades: **(i)** *churning*, em infração à Instrução CVM nº 08/1979, inciso I c/c inciso II, alínea “c”²; e **(ii)** utilização de senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo de cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico, em infração à então vigente Instrução CVM nº 497/2011, art. 13, inciso VII³.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, quando não estiverem aqui definidos, têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² “I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardis ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;”

³ “Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2º: (...) VII - usar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do cliente para transmissão de ordens por meio de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

2. Como indicado no Relatório, a despeito de haver sido regularmente citado, o Acusado não apresentou defesa, de modo que o presente voto se baseia, exclusivamente, nas provas que foram acostadas aos autos durante a fase investigativa que precedeu a Acusação. Em sede de processo administrativo sancionador no âmbito da CVM, contudo, a revelia não importa em confissão quanto a qualquer matéria de fato, tampouco torna incontroversas as alegações da acusação⁴, que permanece com o ônus de trazer aos autos elementos robustos de materialidade e autoria suficientes a amparar as imputações formuladas.

3. A tese acusatória sustenta, em síntese, que Thompson Schemes, na condição de agente autônomo de investimento responsável pelo atendimento da investidora K.M.S. no âmbito da Intermediária, teria realizado sucessivas operações de compra e venda de valores mobiliários não autorizadas no período de julho de 2012 a janeiro de 2013, mediante a utilização de senha de uso exclusivo da investidora, com o intuito de gerar receitas de corretagem, o que evidenciaria a prática das infrações objeto deste Processo.

4. Início meu voto com breves considerações a respeito do conjunto fático-probatório carreado aos presentes autos. Em seguida, adentro o mérito do caso, examinando, sucessivamente, a suposta prática, pelo Acusado, das condutas de (i) negociação excessiva de ativos de propriedade da investidora K.M.S. com a finalidade de gerar receitas de corretagem, prática conhecida como *churning*; e (ii) utilização de senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo da investidora K.M.S. para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico. Por fim, passo à conclusão.

II. Considerações sobre o conjunto fático-probatório

5. O conjunto fático-probatório juntado aos autos durante a fase investigativa que antecedeu o presente Processo tornou, no meu entender, os seguintes fatos incontroversos: (i) a investidora K.M.S. efetivamente abriu uma conta junto à Intermediária⁵ e transferiu à respectiva

sistema eletrônico;" A Instrução CVM nº 497/2011 foi revogada pela Resolução CVM nº 16/2021. O art. 18, inciso VII, da nova resolução tem redação idêntica à do referido art. 13, inciso VII, da instrução revogada.

⁴ Consoante previsto, à época da citação, no art. 28 da Instrução CVM nº 607/2019 e, atualmente, no art. 28 da Resolução CVM nº 45/2021. *In verbis*: "Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, sem direito à repetição dos atos já praticados."

⁵ A ficha cadastral da investidora K.M.S. junto à Intermediária encontra-se datada de 29.05.2012 (Doc. SEI 0725647, fls. 149-150).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

custódia carteira de ações de sua propriedade em 25.06.2012⁶; **(ii)** o Acusado é agente autônomo de investimento credenciado junto à CVM⁷ e foi responsável pelo atendimento da investidora K.M.S., no âmbito da Intermediária, no período de julho de 2012 a janeiro de 2013⁸; **(iii)** o Acusado é sobrinho da investidora K.M.S. e primo-irmão da Reclamante⁹; **(iv)** há registros formais de autorização da investidora K.M.S. quanto a negócios de compra e venda de valores mobiliários realizados a partir de sua conta junto à Intermediária nos meses de julho, novembro e dezembro de 2012¹⁰; **(v)** não há qualquer registro formal de autorização da investidora K.M.S. quanto aos negócios realizados nos meses de setembro e outubro de 2012; **(vi)** nos meses de setembro e outubro de 2012, foi realizado um número maior de negócios com ativos da investidora K.M.S. do que nos demais meses de suposto cometimento das infrações¹¹; e **(vii)** a investidora K.M.S. faleceu em 27.01.2013¹².

6. A partir de uma análise minuciosa do Processo, são esses – e apenas esses – os fatos que se encontram efetivamente comprovados.

7. Nesse sentido, como será explicado em maiores detalhes neste voto, sob uma perspectiva probatória, entendo que alguns dos elementos centrais utilizados pela Acusação

⁶ Figurou como anexo à Reclamação documento endereçado à investidora K.M.S. intitulado “*Confirmação de Movimentação de Ativos*”, expedido em papel timbrado da então denominada BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, que informa a transferência, em 25.06.12, de carteira de ações de propriedade da investidora K.M.S. para a custódia da Intermediária, na Central Depositária BM&FBOVESPA (Doc. SEI 0725647, fl. 20).

⁷ Consta dos autos ficha cadastral de Thompson Schemes junto à CVM, a qual indica o respectivo credenciamento como agente autônomo de investimento em 23.09.2009 (Doc. SEI 0725647, fls. 124-125).

⁸ Informação extraída da Reclamação (Doc. SEI 0725647, fl. 8, item 21) e confirmada de modo expreso na manifestação prévia da Intermediária constante do Processo Originário (Doc. SEI consta exclusivamente dos autos do Processo Originário, não tendo sido reproduzida nos autos deste Processo (Doc. SEI 0725914, fls. 2-3, item 4.2; fls. 118-119, 140-142).

⁹ Informação extraída de diversas manifestações da Intermediária no âmbito do Processo Originário (Doc. SEI 0725647, fls. 118-119 e 140-142 e Doc. SEI 0725914, fls. 2-3, item 4.2) e confirmada em manifestação subsequente da Reclamante (Doc. SEI 0725647, fls. 169-170 e 176-178).

¹⁰ Trata-se de transcrições de ordens de compra e venda de valores mobiliários transmitidas pela investidora K.M.S. ao Acusado via aplicativo de mensagens desenvolvido pela Intermediária, referentes ao período em questão (Doc. SEI 0725647, fls. 24-26).

¹¹ Notas de corretagem das operações realizadas a partir da conta da investidora K.M.S. junto à Intermediária (Doc. SEI 0725647, fls. 28 a 97) revelam, no que diz respeito ao período de suposto cometimento das infrações objeto deste processo (julho de 2012 a janeiro de 2013), que **(i)** houve poucas negociações, em 3 pregões apenas, de 02.07.2012 a 12.07.2012; **(ii)** não houve negociações entre 13.07.2012 e 30.08.2012; **(iii)** houve muitos negócios, em 30 pregões, entre 31.08.2012 e 01.11.2012; e **(iv)** mais uma vez, houve poucas negociações, em 7 pregões, de 02.11.2012 a 27.01.2013.

¹² Conforme Escritura de Inventário e Adjudicação de Bens do Espólio da investidora K.M.S. lavrada em 26.12.2013 e anexada à Reclamação, a investidora K.M.S. “faleceu em 27/01/2013 na cidade do Rio de Janeiro aos 61 (sessenta e um) anos conforme certidão de óbito expedida pelo 5º RCPN do Rio de Janeiro (...)” (Doc. SEI 0725647, fl. 11).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

para tentar sustentar as infrações imputadas a Thompson Schemes vão além do que está efetivamente comprovado nos autos. Tais elementos, a meu ver, não passam de alegações da Reclamante, sem o devido amparo probatório, ou de indícios aos quais não considero adequado conferir valor relevante neste caso, como passo a expor.

8. A tese acusatória baseia-se, em larga medida, nas seguintes premissas fáticas: **(i)** o Acusado deteria o *login* e a senha de acesso da investidora K.M.S. à conta que mantinha junto à Intermediária, conforme comprovaria um documento que, segundo a Reclamante, seria uma mensagem de correio eletrônico juntada aos autos¹³; e **(ii)** a investidora K.M.S. teria sido acometida por grave enfermidade e teria sido hospitalizada nos meses que antecederam sua morte, sendo que, durante esse período, também de acordo com a Reclamante, seu estado de saúde teria se deteriorado progressivamente até que K.M.S. haveria se tornado inconsciente, sem qualquer condição de determinar sua vontade, tendo ao fim falecido em 27.01.2013.

9. Por oportuno, reproduzo abaixo os termos da mensagem referida no item (i) do parágrafo anterior:

“Oi Pat, tudo bom?

o e-mail que eu criei é o [Ilegível] a senha é paula202 (pra eu não esquecer, rss), entrando no e-mail você verá um e-mail da [Intermediária], contendo seu login e senha.

Estou te passando em anexo um doc que preciso pegar assinado contigo, é a transferência das ações, te falei que iríamos transferir o saldo mas não vai ser possível, vamos transferir as ações.

O site da [Intermediária] é o [•].

Qualquer dúvida me da uma ligada no celular,

bjo,

Thompinho”

10. À primeira vista, o conteúdo da mensagem em tela parece sugerir que a relação entre o Acusado e a investidora K.M.S. seria de um vínculo próximo e poderia corroborar a alegação constante da Reclamação no sentido de que o Acusado deteria – ou ao menos deteve, nos momentos que antecederam o envio da mensagem – o *login* e a senha de acesso da investidora K.M.S. à sua conta junto à Intermediária.

¹³ Doc. SEI 0725647 (fl. 22) e Doc. SEI 0725914 (fl. 41).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

11. A respeito de tal mensagem e do valor probatório que lhe é atribuído pela tese acusatória, transcrevo abaixo trecho extraído da seção conclusiva da Acusação¹⁴:

“31. Pelo email juntado pela denunciante, presente também na manifestação da [Intermediária], é possível observar um grande grau de intimidade e confiança que aparenta haver entre Thompson e a investidora, sua tia (0725647, fl. 22 e 0725914, fl. 03).

32. Também pode ser visto que Thompson afirma ter criado o email de contato com a corretora e informa que ‘entrando no e-mail você verá um e-mail da [Intermediária], contendo login e senha’, ou seja, Thompson estava de posse do login e da senha da investidora na [Intermediária] e, segundo sua vontade, poderia acessar a corretora em nome da investidora e transmitir ordens para a negociação de valores mobiliários, tanto através do home broker quanto pelo [Intermediária] Messenger.

33. De acordo com os documentos apresentados pela [Intermediária], as ordens para negociação de ações em nome da investidora não foram transmitidas através do home broker, mas pelo aplicativo [Intermediária] Messenger, que também necessitaria de acesso à conta, através de login e senha.

34. A capacidade de Thompson para acessar o aplicativo [Intermediária] Messenger e atuar em nome da investidora justifica a desconfiança da denunciante sobre uma possível fraude em relação às mensagens trocadas com Thompson através desse aplicativo.”

12. Contudo, o que efetivamente desperta a minha atenção não é o conteúdo propriamente dito de tal documento apresentado na Reclamação como sendo um e-mail, mas, sim, o fato de que dele não consta qualquer cabeçalho padronizado. De forma diferente daqueles usualmente constantes de e-mails enviados, não é possível extrair um conjunto mínimo de informações que torne razoavelmente crível que a mensagem em questão efetivamente foi remetida, como a data e o horário do respectivo envio ou ainda os nomes e endereços de correio eletrônico de remetente, destinatários principais e em cópia. Não consta dos autos qualquer outra comprovação do envio ou do recebimento do correio eletrônico em questão.

13. À luz de tal singular circunstância fática, não me parece adequado considerar verossímil que o Acusado efetivamente tenha estado de posse do *login* e da senha de acesso da investidora K.M.S. à sua conta junto à Intermediária, como faz a Acusação.

14. Passo, em seguida, à análise da premissa (ii) acima referida, relativa ao estado de saúde da investidora K.M.S. nos meses que antecederam seu óbito, em 27.01.2013. A esse respeito, o

¹⁴ Doc. SEI 0883611 (fl. 4).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

único fato efetivamente comprovado e incontroverso neste Processo é a data de falecimento da investidora K.M.S. (27.01.2013)¹⁵. Não foram juntados aos presentes autos quaisquer outros documentos ou meios de prova – como simples atestados, laudos ou prontuários médicos de qualquer natureza –, com base nos quais poderia ser possível aferir em bases minimamente consistentes, por exemplo, o real estado de saúde da investidora K.M.S. e respectiva evolução de julho de 2012 a janeiro de 2013; ou o período de sua suposta hospitalização. São fatos que poderiam ser provados com razoável facilidade.

15. Nesse contexto, à míngua de elementos probatórios com alguma consistência que lhe possam emprestar grau mínimo de confiabilidade, principalmente no contexto de um processo administrativo sancionador, não me parece razoável reputar como comprovadas as alegações extraídas da Reclamação relativas à progressiva deterioração do estado de saúde da investidora K.M.S. e assumir de plano, como faz a Acusação, que K.M.S. estivesse “hospitalizada” e “em situação extremamente vulnerável em vista de grave enfermidade”¹⁶ – sem qualquer inquirição ou questionamento de prova de outra natureza que pudesse corroborar o alegado.

16. Retomarei essas considerações fáticas introdutórias ao longo do presente voto. Por ora, adianto apenas que não identifiquei, nos autos, indícios suficientemente robustos e convergentes a amparar a tese da Área Técnica que propõe a condenação do Acusado.

III. Mérito

Negociação excessiva (churning)

17. No presente processo, Thompson Schemes é acusado da prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários em razão da suposta conduta de negociação excessiva – ou *churning* – no que diz respeito à carteira de ações de propriedade da investidora K.M.S. no período de julho de 2012 a janeiro de 2013.

18. Como bem apontado na Acusação, a prática de *churning* é usualmente conceituada como uma “modalidade de fraude na qual pessoas se valem do controle que exercem sobre recursos de terceiros para fazer com que esses sejam negociados de modo excessivo, visando

¹⁵ Vide nota de rodapé nº 12.

¹⁶ Doc. SEI 0883611 (fl. 4, itens 37.2 e 35, respectivamente).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

não ao melhor interesse do investidor, mas a gerar taxas e comissões para si ou para outrem”¹⁷.

19. Tal prática configura operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, na qual o ardil “*negociação excessiva*” se alia à manutenção de investidor em erro com a finalidade de obter, para si ou para outrem, a vantagem patrimonial ilícita consubstanciada em taxas ou comissões. Tudo isso nos termos do inciso I da Instrução CVM nº 08/1979, conforme o conceito do inciso II, alínea “c”, do referido normativo¹⁸. Trata-se, ainda, de infração de natureza grave, de acordo com o inciso III do mesmo diploma regulamentar.

20. Conforme precedentes deste Colegiado¹⁹, a configuração do ilícito exige a presença cumulativa dos seguintes elementos: **(i)** controle sobre as operações cursadas em nome do investidor; **(ii)** giro excessivo da carteira de investimentos à luz do perfil do cliente; e **(iii)** intenção de gerar receitas de corretagem ou outras comissões.

21. O controle sobre as operações do cliente é fundamental à caracterização da prática de *churning*. Com efeito, apenas o fato de a conta ter sido girada em patamares excessivos, incompatíveis com o perfil do investidor, usualmente não configura fraude caso o próprio titular da conta tenha, de forma consciente, realizado ou autorizado as operações.

22. Penso ser possível, para fins de sistematização, decompor o elemento “*controle*” em duas modalidades distintas: **(i)** controle de direito, verificado quando o agente desfruta de discricionariedade outorgada pelo investidor para tomar decisões de investimento em virtude de uma prévia relação jurídica existente, válida e eficaz, como seria o caso de um contrato de administração de carteira; e **(ii)** controle de fato, verificado quando, a despeito de inexistir a transferência formal e regular de recursos à gestão do agente, este ainda assim a realiza, seja *(a)* de forma desconhecida ou não autorizada pelo investidor, seja ainda *(b)* caso o próprio

¹⁷ Definição extraída pela Acusação (Doc. SEI 0883611, fl. 4, item 36) de palestra proferida pelo ex-diretor da CVM Gustavo Gonzalez na ANCORD - Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias em 25.03.2019, cujo conteúdo também consta dos presentes autos (Doc. SEI 0819949, fls. 3).

¹⁸ Vide nota de rodapé nº 2.

¹⁹ Vide, nesse sentido: **(i)** PAS CVM nº 11/2013, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 30.01.2018; **(ii)** PAS CVM nº RJ2015/6143, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 24.04.2018; **(iii)** PAS CVM nº SP2014/0465, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 06.11.2018; **(iv)** PAS CVM nº RJ2014/12921, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 10.02.2017; e **(v)** PAS CVM nº SP2014/0382, Diretor Relator Henrique Machado, julgado em 09.10.2018. Destaco que, nos três primeiros precedentes citados, de relatoria do Diretor Gustavo Gonzalez, os elementos da infração se apresentam sistematizados exatamente conforme apresentado neste voto. Já nos dois precedentes seguintes, de relatoria dos Diretores Pablo Renteria e Henrique Machado, os mesmos três requisitos são levados em conta, embora não se apresentem sistematizados dessa forma.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

investidor tome suas decisões de investimento e desinvestimento, porém, induzido em erro pelo agente; nessa modalidade, o investidor, por não possuir experiência no mercado de capitais, deposita sua confiança no agente, acatando reiteradamente suas sugestões²⁰.

23. Voltando ao caso concreto, a Acusação sustenta que Thompson Schemes detinha o controle de fato da conta da investidora K.M.S. a partir de 3 elementos²¹: (i) posse, pelo Acusado, de *login* e senha de acesso da investidora K.M.S. à sua conta junto à Intermediária, situação que seria comprovada a partir do documento que foi apresentado pela Reclamante como um correio eletrônico²²; (ii) estado vulnerável de saúde da investidora K.M.S., que se encontrava hospitalizada em virtude de grave enfermidade, situação apenas informada na Reclamação, sem qualquer suporte documental ou de outra natureza que pudesse confirmar o alegado; e (iii) completa ausência de registro da autorização de tal investidora em relação aos negócios executados pelo Acusado entre setembro e outubro de 2012. Tais elementos, conjugados, segundo a Acusação, supostamente evidenciariam que o Acusado usou a senha da investidora K.M.S. para a realização de negócios por ela não autorizados.

24. Nada obstante, a meu ver, o conjunto probatório trazido aos autos pela Acusação não autoriza tal conclusão.

25. Primeiro: como tive a oportunidade de demonstrar em detalhes na seção anterior deste voto, a mensagem apontada pela Acusação como elemento supostamente comprobatório da posse do Acusado em relação ao *login* e à senha de acesso da investidora K.M.S. à sua conta junto à Intermediária não me parece reunir elementos mínimos que permitam tornar crível que tal mensagem efetivamente tenha sido enviada. Portanto, ausentes outros elementos probatórios dos autos, reputo como não comprovada a posse em questão.

²⁰ A classificação sugerida por mim neste voto foi inspirada, essencialmente, a partir de elementos constantes do voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez no PAS CVM nº SP2014/465. Destaco, em especial, a seguinte citação, extraída do voto em questão: “*Churning, in essence, involves a conflict of interest in which a broker or dealer seeks to maximize his or her remuneration in disregard of the interest of the customer. The brokerdealer is most likely to have control over the customers’ account to exploit this conflict of interest when the customer has expressly granted to the broker-dealer discretionary authority to trade. Control can exist also in a nondiscretionary account when the broker-dealer in fact exercises discretion over the account either because of unknown or unauthorized trades or because the customer routinely accepts the broker-dealer’s recommendations, typically because the customer is naïve, unsophisticated, or inexperienced.*” (grifos meus) (LOSS, Louis; SELIGMAN, Joel; PAREDES, Troy. Securities Regulation. Fourth Edition, Volume VIII. Nova York: Wolters KluwerLaw & Business, 2012, pp. 427-428, *apud* PAS CVM nº SP2014/465, voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 06.11.2018).

²¹ Doc. SEI 0883611 (fl. 4, em especial itens 31-35 e 37.1).

²² Doc. SEI 0725647 (fl. 22) e Doc. SEI 0725914 (fl. 41).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

26. Segundo: como igualmente expus na seção precedente deste voto, não foram juntados aos presentes autos quaisquer documentos ou meios de prova com base nos quais pudesse ser aferido (i) o real estado de saúde da investidora K.M.S. e respectiva evolução de julho de 2012 a janeiro de 2013; ou (ii) o período de sua suposta hospitalização.

27. Terceiro: o fato de que não consta do Processo registro de autorização da investidora K.M.S., em relação aos negócios executados pelo Acusado entre setembro e outubro de 2012, não me parece, isoladamente considerado, apto a autorizar a conclusão de que o Acusado detinha o controle sobre as operações cursadas em nome da investidora K.M.S.

28. O segundo elemento caracterizador da prática do *churning* consiste na prática de negócios excessivos à luz do perfil do investidor.

29. Para a demonstração da excessividade da negociação, a Acusação, amparada em estudo desenvolvido pela BSM em 2011 (“Estudo BSM”)²³, faz uso de dois indicadores cuja utilização vem sendo prestigiada na jurisprudência deste Colegiado²⁴, a saber:

- (i) a taxa de giro da carteira, ou *turnover ratio* (“TR”), destinada a aferir se o volume de negócios realizado com a carteira do cliente foi excessivo, a qual, nas palavras do Estudo BSM, “*indica o número de ‘giros’ efetuados com a carteira do cliente, comparando-se o patrimônio médio do cliente com o volume total de compras efetuado. Como benchmark para verificar se determinada Turnover Ratio é excessiva, sugere-se compará-la com a taxa de turnover dos fundos de investimento em ações, partindo-se do princípio de que é razoável supor que um investidor particular gire sua carteira a taxa inferior à de fundos geridos por profissionais. De acordo com os cálculos efetuados, taxas de turnover superiores a 8 [vezes] seriam fortemente indicativas da prática de churning, não podendo-se descartar, contudo, a possibilidade de churning para taxas entre 2 e 8 [vezes].*”²⁵; e

²³ O Estudo BSM encontra-se no Relatório de Análise nº 01/2011 (Doc. SEI 0819882).

²⁴ Nesse sentido: (i) PAS CVM nº 24/2010, Diretora Relatora Ana Novaes, julgado em 27.05.2014; (ii) PAS CVM nº SP2012/480, Diretor Relator Roberto Tadeu, julgado em 06.10.2015; (iii) PAS CVM nº RJ2014/2797, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 27.09.2016; (iv) PAS CVM nº RJ2014/12921, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 10.02.2017; (v) PAS CVM nº 11/2013, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 30.01.2018; (vi) PAS CVM nº RJ2015/6143, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 24.04.2018; (vii) PAS CVM nº SP2014/0382, Diretor Relator Henrique Machado, julgado em 09.10.2018; e (viii) PAS CVM nº SP2014/0465, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 06.11.2018.

²⁵ Doc. SEI 0819882 (fls. i-ii).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

- (ii) a razão custo sobre patrimônio, ou *cost-equity ratio* (“C/E” e, quando referida em conjunto com a TR, simplesmente “Indicadores BSM”), destinada a aferir se o montante total de despesas incorridas pelo investidor foi demasiado, a qual, também nas palavras do Estudo BSM, “*compara o total de despesas que incidiu sobre a carteira do investidor com seu patrimônio médio*” e “*reflete o retorno mínimo que seria necessário para cobrir as despesas que incidiram sobre a carteira do investidor em determinado período. Como base de comparação para verificar se determinada cost-equity ratio é elevada ou não, sugere-se compará-la com a rentabilidade histórica do Ibovespa, que, nos últimos 15 anos, foi de, aproximadamente, 21% ao ano. Ou seja, cost-equity ratios superiores a 21% ao ano seriam consideradas como indicativas da prática de churning, vez que reduziriam a probabilidade do investidor obter algum lucro a menos de 50%.*”²⁶

30. Portanto, o Estudo BSM sugere que uma TR anualizada superior a 8 vezes e uma C/E superior a 21% ao ano são indícios da prática fraudulenta. No caso concreto, ambos os Indicadores BSM foram em muito ultrapassados: cálculos efetuados pela BSM a partir das operações de compra e venda de valores mobiliários realizadas em nome da investidora K.M.S. no período de julho de 2012 a janeiro de 2013 revelaram uma TR anualizada de 62,53 vezes e uma C/E, também anualizada, de 49,19%²⁷.

31. Os Indicadores BSM são, contudo, apenas modelos gerais, que devem sempre ser analisados à luz de diversas outras situações específicas do caso concreto, inclusive do perfil do cliente²⁸⁻²⁹. Quanto ao perfil da investidora K.M.S., a Acusação pontua que “[n]o que se

²⁶ Doc. SEI 0819882 (fl. ii).

²⁷ Os cálculos em questão foram encaminhados por Ofício da BSM de 11.10.2019 (Doc. SEI 0859965) e constam de planilha que também integra os presentes autos (Doc. SEI 0859966).

²⁸ A ex-diretora Ana Novaes salientou a necessidade de que os administradores conheçam os interesses de seus clientes e pautem suas atividades em benefício deles: “*É óbvio que as corretoras e distribuidoras devem ter o mínimo conhecimento sobre quem são os seus clientes, no caso um fundo de pensão de servidores municipais, e podem facilmente avaliar se o giro excessivo de uma carteira não seria excessivo diante de um custo de corretagem que claramente era prejudicial ao cliente e favorável à própria C&D*” (PAS CVM nº 24/2010, Diretora Relatora Ana Novaes, julgado em 27.05.2014)

²⁹ “*Por ora, cumpre ressaltar que os indicadores TR e C/E fornecem apenas indícios de churning e nem sempre bastarão para demonstrar a prática do ilícito. O fato de a carteira ter sido mais movimentada do que a média de mercado (seja essa qual for) ou de os custos incorridos nas negociações terem consumido uma parcela expressiva do patrimônio investido não denotam, necessariamente, uma irregularidade. Afinal de contas, o perfil do investidor (ou do fundo ou clube de investimento, conforme o caso) e os seus objetivos com aquele investimento são as melhores medidas para aferir se o giro foi, de fato, excessivo.*” (PAS CVM nº 11/2013, Relator Diretor Gustavo Gonzalez, julgado em 30.01.2018) (grifos meus).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

refere ao perfil da investidora, cabe ressaltar que se tratava de investidora idosa e hospitalizada, situação incompatível com esse giro.”

32. Como tive a oportunidade de indicar anteriormente neste voto, inexistem, nos presentes autos, qualquer prova da alegação de que a investidora K.M.S. tenha, em algum momento, sido hospitalizada. O que restou comprovado foi que tal investidora faleceu aos 61 anos de idade em 27.01.2013³⁰. Entendo que a idade da investidora K.M.S. quando do seu falecimento e nos meses que precederam tal acontecimento pouco esclarece a respeito do seu real perfil de investidora – ressaltando que o óbito ocorreu quando a investidora possuía idade ainda distante daquela que poderia ser considerada mais avançada e que pudesse, *de per si*, reforçar a percepção de que não haveria mais condições de interação com seu agente autônomo de investimento, participação ou acompanhamento das operações.

33. O conjunto fático-probatório carreado aos autos tampouco auxilia nesse mister: inexistem, no presente Processo, documentos ou informações objetivas que possam esclarecer qual era o real conhecimento da investidora K.M.S. em relação ao mercado de capitais, quais eram suas expectativas e objetivos em relação à carteira de valores mobiliários que detinha ou, ainda, quaisquer outras circunstâncias subjacentes que pudessem, de fato, evidenciar seu perfil como investidora.

34. Nesse sentido, recapitulo a seguir os elementos passíveis de serem extraídos dos autos que se relacionam, de algum modo, com o perfil da investidora K.M.S.: **(i)** ainda na fase investigativa que antecedeu o Processo, a Intermediária deixou de fornecer à CVM a análise do perfil da investidora K.M.S. por alegadamente não ter sido preenchido³¹; **(ii)** a ficha cadastral completa da investidora K.M.S. junto à Intermediária³² aponta que K.M.S. era aposentada quando da abertura de sua conta, mas não indica qual foi sua profissão anteriormente à aposentadoria; **(iii)** constam da ficha cadastral em questão declarações genéricas e padronizadas no sentido de que K.M.S. conhecia *“as normas de funcionamento do mercado de títulos e valores mobiliários, bem como os possíveis riscos envolvidos nas operações realizadas em bolsa de valores, mercadorias e futuros, principalmente no que concerne aos mercados de*

³⁰ Conforme se extrai da já mencionada Escritura de Inventário e Adjudicação de Bens do Espólio da investidora K.M.S. lavrada em 26.12.2013 e anexada à Reclamação, a investidora K.M.S. *“faleceu em 27/01/2013 na cidade do Rio de Janeiro aos 61 (sessenta e um) anos conforme certidão de óbito expedida pelo 5º RCPN do Rio de Janeiro (...)”* (grifos meus) (Doc. SEI 0725647, fl. 11).

³¹ Doc. SEI 0725647 (fl. 145).

³² Doc. SEI 0725647 (fls. 149-150).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

opções e termo”³³; (iv) constam da Reclamação alegações, não comprovadas, de que K.M.S. não teria tido contato prévio com o mercado de capitais que justificasse as supostas expressões e jargões técnicos a ela atribuídos nas transcrições de ordens de compra e venda de valores mobiliários obtidas da Intermediária³⁴; e (v) com base em documentos constante dos autos, extrai-se que a carteira de ações da investidora K.M.S., em 25.06.2012, era avaliada em R\$ 114.693,00 (cento e quatorze mil, seiscentos e noventa e três reais)³⁵ e composta por: (a) 5000 *depository receipts* de emissão de “LAEP”; (b) 3.200 ações ordinárias de emissão de “OGX PETROLEO”; (c) 1500 ações preferenciais de emissão de “PETROBRAS”; e (d) 9.300 ações preferenciais classe “A” de emissão de “USIMINAS”³⁶.

35. Não considero, contudo, possível extrair de tais elementos, isolada ou conjuntamente considerados, informações suficientes a respeito do perfil de K.M.S. como investidora que permitam concluir se os Indicadores BSM relativos ao caso concreto eram compatíveis ou incompatíveis com tal perfil.

36. Na ausência dos referidos elementos, entendo que a presença da excessividade de negociação deve ser avaliada, no presente caso, exclusivamente com base nos Indicadores BSM. Evidentemente, não se pode ignorar que o valor probatório de tais indicadores aumenta na medida em que se afastem dos limites traçados pelo Estudo BSM; ao passo que seu valor diminui com a sua aproximação³⁷.

³³ Doc. SEI 0725647 (fl. 150, item 9).

³⁴ Doc. SEI 0725647 (fl. 6).

³⁵ Informação extraída da petição inicial da Ação Indenizatória com base em cálculos efetuados pela Reclamante (Doc. SEI 0725647, fls. 193, 203 e 207).

³⁶ Informações relativas à composição da carteira da investidora K.M.S. extraídas de documento endereçado a tal intitulado “*Confirmação de Movimentação de Ativos*”, expedido em papel timbrado da então denominada BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, que informa a transferência, em 25.06.12, de carteira de ações de sua propriedade para a custódia da Intermediária, na Central Depositária BM&FBOVESPA (Doc. SEI 0725647, fl. 20).

³⁷ Ainda que os indicadores não sejam provas incontestes da prática de *churning*, não cabe relativizá-los em demasia, uma vez que a metodologia empregada para elaboração dos indicadores partiu de circunstâncias extremas e, portanto, já consubstancia parâmetros elevados. Nesse sentido, o ex-diretor Gustavo Gonzalez pontuou: “*Parece-me claro que, olhando apenas para os índices, quanto maiores esses forem em um caso concreto, maior valor probatório deve a eles ser atribuído. Nos casos em tela, tanto o TR quanto o C/E das carteiras não excederam de modo tão gritante os limites indicados nos estudos de referência, como nos precedentes já julgados pelo Colegiado. Por um lado, não se pode dar a esse fato um peso excessivo – os limites já foram calculados pensando em situações extremas, e considerar que a irregularidade somente resta caracterizada quando os marcos são em muito ultrapassados significa, em última medida, dizer que os referidos marcos pouco valem. Por outro lado, em casos menos extremos, a acusação deve, sempre que possível, buscar outros elementos de prova que corroborem a sua tese.*” (grifos meus) (PAS CVM nº 11/2013, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, j. em 30.01.2018).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

37. Como apontei acima, os cálculos efetuados pela BSM relativos ao presente caso revelaram que os dois parâmetros-limite usualmente utilizados para a caracterização da prática de *churning* no Brasil com base no Estudo BSM – quais sejam, TR anualizada acima de 8 vezes e C/E anualizada acima de 21% – foram em muito superados. A TR anualizada atingiu a marca de 62,53 vezes e a C/E anualizada, o patamar de 49,19%. À luz de tais números, considero haver restado demonstrada a excessividade de negociação *in casu* e entendo estar presente o segundo elemento caracterizador da prática de *churning*.

38. A infração contém, por fim, um terceiro elemento, subjetivo, sem o qual a irregularidade não se perfaz. A prática do *churning* pressupõe dolo, de forma que é preciso verificar se a conduta do agente foi orientada pela finalidade de gerar, ilicitamente, receitas à custa dos interesses do cliente. Dificilmente há prova documental deste requisito, sendo normalmente constatado a partir dos demais elementos da infração. Segundo a Acusação, teria havido “*nítida alteração no perfil das operações cursadas nos momentos que antecederam o falecimento da investidora, o que indica claramente a intenção de Thompson de gerar taxas, aproveitando-se da incapacidade de supervisão da investidora naquele período*”³⁸. O ponto não é desenvolvido.

39. Discordo da Acusação nesse particular. Embora, de fato, conste dos autos comprovação de que um maior número de operações foi realizado³⁹ a partir da conta da investidora K.M.S. nos meses de setembro e outubro de 2012, não restou evidenciada qualquer incapacidade de supervisão da investidora K.M.S. no mesmo período, como tive a oportunidade de expor na seção precedente deste voto. Também não identifiquei neste Processo qualquer outro elemento que pudesse, direta ou indiretamente, demonstrar a intenção de gerar receitas de corretagem ou outras comissões no presente caso.

40. Por todo o exposto, entendo que não estão atendidos, no presente caso, dois dos três elementos de prova necessários à configuração da prática de *churning*, quais sejam, o controle sobre as operações cursadas em nome do investidor; e a intenção de gerar receitas de corretagem ou outras comissões. Nessa ordem de raciocínio, embora presente inequivocamente o elemento de giro excessivo da carteira de investimentos, inexistente conjunto probatório suficiente para a condenação do Acusado pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários em razão da suposta conduta de negociação excessiva.

³⁸ Doc. SEI 0883611 (fl. 4, item 37.3).

³⁹ Vide nota de rodapé nº 11.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Utilização de senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo de cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico

41. Thompson Schemes é também acusado da prática de uma segunda infração neste Processo, qual seja, a utilização de senha eletrônica de uso exclusivo da investidora K.M.S. para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico, também no período de julho de 2012 a janeiro de 2013, em suposta infração ao art. 13, inciso VII, da então vigente Instrução CVM nº 497/2011.

42. Nos termos da Acusação, seria *“possível concluir com razoável certeza que, ao menos no período em que a investidora esteve hospitalizada, quando houve negociações quase diárias em nome dela, Thompson utilizou a senha de sua cliente para a transmissão de ordens, desrespeitando o art. 13, VII, da Instrução CVM nº 497, infração grave para efeito do disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, de acordo com o art. 23, III, da Instrução.”*⁴⁰.

43. Observo, em primeiro lugar, que a imputação em questão parece encontrar fundamento nos mesmos elementos utilizados pela Acusação para sustentar que Thompson Schemes deteria o controle sobre as operações cursadas em nome da investidora K.M.S., a saber: (i) posse, pelo Acusado, de *login* e senha de acesso da investidora K.M.S. à sua conta junto à Intermediária, supostamente comprovada a partir do que a Reclamante apresentou como um correio eletrônico; (ii) estado vulnerável de saúde da investidora K.M.S., que se encontrava hospitalizada em virtude de grave enfermidade, também de acordo exclusivamente com o relato da Reclamação; e (iii) completa ausência de registro da autorização de tal investidora em relação aos negócios executados pelo Acusado entre setembro e outubro de 2012. Tais elementos, conjugados, para a Acusação, supostamente evidenciariam que o Acusado teria utilizado a senha de uso exclusivo da investidora K.M.S. para a transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico e realização de negócios por ela não autorizados.

44. Como tive a oportunidade de demonstrar anteriormente neste voto, o conjunto fático-probatório carreado aos autos não permite concluir, com mínimo grau de certeza, que o Acusado teve acesso ao *login* e à senha de acesso da investidora K.M.S. à sua conta junto à Intermediária, nem que K.M.S. tenha de fato estado vulnerável e hospitalizada no período de suposto cometimento das infrações (elementos “i” e “ii” do parágrafo anterior).

⁴⁰ Doc. SEI 0883611 (fl. 5).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

45. Em relação à ausência de registros quanto à autorização dos negócios executados pelo Acusado entre setembro e outubro de 2012 (elemento “iii” do parágrafo anterior), repito tratar-se de fato incontroverso no presente Processo. Nada obstante, esse elemento, isoladamente considerado, não me parece autorizar, sob uma perspectiva lógica e jurídica, a inferência de que o Acusado tenha se utilizado da senha de acesso da investidora K.M.S. para realizar negócios não autorizados.

46. Até porque, a se entender que a inexistência de registro das referidas autorizações autorizaria, por si só, a conclusão de que o Acusado se utilizou da senha de uso exclusivo da investidora K.M.S. para transmissão de ordens e infringiu o art. 13, inciso VII, da Instrução CVM nº 497/2011, estar-se-ia atribuindo à falta de documentação (relativa aos meses de setembro e outubro de 2012) peso maior do que aquele que se atribuiu à documentação que existe nos autos (relativa aos meses de julho, novembro e dezembro de 2012)⁴¹ e que favorece o Acusado, o que não me parece coerente ou mesmo adequado, em homenagem ao princípio do *in dubio pro reo*.

47. Pelo acima exposto, não vislumbro fundamento no conjunto fático-probatório trazido aos autos para a condenação do Acusado pela suposta utilização de senha eletrônica de uso exclusivo da investidora K.M.S. para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico.

48. Por fim, considero relevante adicionar, em relação a essa segunda infração, que, *in casu*, ela parece estar absorvida pela própria infração de negociação excessiva. A utilização de senha de uso exclusivo da investidora K.M.S. para transmissão de ordens por sistema eletrônico, no máximo, pode ter representado o meio de que o Acusado se valeu para a prática do *churning*. Dito de outro modo, a infração-fim no presente caso concreto parece ser a prática da negociação excessiva, mas esse desiderato final teria supostamente sido atingido por meio da prática da infração-meio, caracterizada pela utilização de senha eletrônica de uso exclusivo da investidora K.M.S. para transmissão de ordens.

49. Portanto, buscando subsídios no direito penal, entendo ser aplicável ao caso o princípio da consunção ou absorção. A consunção lida com situações de concurso aparente de normas, preconizando que, quando um crime é praticado como meio para o atingimento de um crime

⁴¹ Doc. SEI 0725647 (fls. 24-26).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

final, em que se esgota o seu potencial lesivo, o “crime-meio” é absorvido pelo “crime-fim”⁴²-
43.

50. Assim, entendo forçoso reconhecer no presente caso, em respeito ao princípio da consunção, que o Acusado deve ser julgado apenas com fundamento na acusação da prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários em razão da suposta conduta de negociação excessiva ou *churning*.

IV. Conclusão

51. A Acusação sustenta, em síntese, que Thompson Schemes, na qualidade de agente autônomo de investimento responsável pelo atendimento à investidora K.M.S. no âmbito da Intermediária, teria realizado sucessivas operações de compra e venda de valores mobiliários não autorizadas por tal investidora no período de julho de 2012 a janeiro de 2013, mediante a utilização de senha de uso exclusivo da investidora e com o intuito de gerar receitas de corretagem, o que evidenciaria a prática das infrações objeto deste Processo.

52. Pelas razões que expus de modo detalhado ao longo deste voto, entendo que os principais elementos de prova articulados pela Acusação para amparar as infrações imputadas a Thompson Schemes (i) consistem em meras alegações extraídas da Reclamação e não comprovadas no presente Processo (como é o caso das alegações relativas ao suposto estado de saúde da investidora K.M.S., ao período de sua hospitalização ou ainda à sua alegada não familiaridade com o mercado de capitais); ou (ii) configuram simples indícios aos quais não considero adequado conferir maior valor probatório neste caso (como é o caso do que a

⁴² Vide, nesse exato sentido, o voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez no PAS RJ2016/7961, julgado em 30.01.2020.

⁴³ A respeito do princípio em comento, leciona Cezar Roberto Bittencourt que: “*Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração. Por isso, o crime consumado absorve o crime tentado, o crime de perigo é absorvido pelo crime de dano. A norma consuntiva constitui fase mais avançada na realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio major absorbet minorem. Assim, as lesões corporais que determinam a morte são absorvidas pela tipificação do homicídio, ou o furto com arrombamento em casa habitada absorve os crimes de dano e de violação de domicílio etc. A norma consuntiva exclui a aplicação da norma consunta, por abranger o delito definido por esta. Há consunção quando o crime-meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a punição somente da conduta criminosa final do agente.*” (grifos meus). (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral 1, 24. Ed., 2ª tiragem, São Paulo: Saraiva Educação, 2018, fls. 266-267).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Reclamante considerou uma mensagem eletrônica, que alegadamente comprovaria a posse, pelo Acusado, da senha de acesso da investidora K.M.S. à sua conta junto à Intermediária). As provas trazidas pela Acusação que efetivamente resistem a um exame crítico – quais sejam, a ausência do registro formal da autorização da investidora K.M.S. quanto aos negócios executados nos meses de setembro e outubro de 2012; e os Indicadores BSM relativos ao caso concreto – não me parecem, contudo, autorizar a conclusão da prática das infrações objeto deste Processo.

53. Em síntese, entendo que não existem, no Processo, provas conclusivas das infrações de *churning* e de utilização de senha eletrônica de uso exclusivo do cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico. Não há sequer prova indiciária, na medida em que inexistem, nestes autos, um conjunto de indícios suficientemente robusto, sólido e convergente que permita superar qualquer dúvida razoável a respeito da materialidade e da autoria das condutas imputadas ao Acusado⁴⁴⁻⁴⁵⁻⁴⁶.

⁴⁴ Como tive a oportunidade de destacar em manifestação de voto anterior: “Desde que observados certos requisitos, os indícios podem desempenhar papel importante nos processos administrativos sancionadores junto à CVM. Já são confortavelmente conhecidos os parâmetros deles exigidos para que de fato possam ter alguma utilidade como elemento de prova, cabendo destaque para aspectos de pluralidade, robustez, solidez e convergência. (...) Logo, é preciso que o indício não deixe qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e autoria do fato principal (beyond a reasonable doubt – BARD). A pluralidade, robustez e convergência de indícios ajuda, como dito acima, a superar a dúvida razoável. Como esses são elementos que exigem a verificação de mais de um indício, podemos dizer que um indício isoladamente considerado dificilmente poderia ser suficiente para uma condenação.” (PAS CVM nº 05/2014, Diretor Relator Henrique Machado, citação extraída do voto-vista de minha autoria, acompanhado pelos demais membros do Colegiado, com exceção do Diretor Relator, julgamento concluído em 15.06.2021).

⁴⁵ Em sentido similar, a Diretora Flávia Perlingeiro afirmou no voto que proferiu no PAS CVM nº RJ2015/9443, de sua relatoria: “há muito se admite na CVM a prova indireta para se chegar à conclusão sobre o uso de informações privilegiadas, já tendo se consolidado entendimento do Colegiado de que deve prevalecer nesses casos o princípio do livre convencimento motivado, sendo possível a condenação com base em prova indiciária, desde que haja um robusto concurso de indícios (comprovados, independentes e convergentes), que permita alcançar uma conclusão segura a respeito da ilicitude da conduta, não sendo imprescindíveis provas cabais.” (PAS CVM no RJ2015/9443, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 04.06.2019).

⁴⁶ Sem prejuízo da independência entre as instâncias administrativa e judicial e a diferença de objeto entre o presente Processo e a Ação Indenizatória, registro que a falta de suporte probatório também parece ter sido elemento presente na ação judicial em tela, conforme reconhecido na parte dispositiva da respectiva sentença, proferida em 13.06.2019. *In verbis*: “O feito está maduro para sentença. Finda a instrução probatória, não se vislumbra conduta da [Intermediária] ou de seus prepostos que possa acarretar a responsabilização pretendida. Investimentos no mercado de ações se caracterizam pelo risco, com ganhos sedutores e prejuízos iminentes, por isso, nem todos têm perfil para atuar neste tipo de investimento. E, por esta mesma razão, o cadastro em corretora é precedido de enquadramento de perfil de risco. A autora alega que a atuação de um agente da ré, causou prejuízos a sua mãe e à autora, única herdeira desta. E apresenta como fundamentos para tal alegação: que a mãe da autora não conhecia o mercado financeiro e teria sido levada a operar nele pelo agente da [Intermediária]; que sua mãe estava enferma, depois hospitalizada e inconsciente e não poderia ter enviado mensagens para o agente; que sua mãe não foi a autora das mensagens porque esta desconheceria o jargão do mercado; que foram feitas operações após o falecimento de sua mãe. Em primeiro lugar, observo que não há nos autos qualquer



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

54. Por oportuno, registro uma vez mais a nítida relação existente entre as infrações objeto da Acusação no presente Processo, a impor o reconhecimento da consunção da infração-meio (utilização da senha eletrônica de uso exclusivo da investidora K.M.S. para transmissão de ordens por sistema eletrônico) pela infração-fim (*churning*).

elemento comprobatório do período de hospitalização da mãe da autora ou de seu estado de inconsciência alegados na inicial. De acordo com a certidão de óbito juntada, a mãe da autora faleceu jovem, aos 61 anos de câncer no pulmão, com o qual conviveu por 08 anos, segundo depoimento prestado às fls. 395/397. Por outro lado, os documentos trazidos aos autos não revelam que sua mãe fosse inexperiente ou desconhecesse o mercado. Muito pelo contrário. A mãe da autora, aos 61 anos, mantinha perfil na rede social Facebook, com postagens frequentes e comentários conforme fls. 193/199. Assim, não é verossímil crer que a mãe da autora não soubesse como enviar mensagens para seu agente de mercado. A mãe da autora firmou o termo de adesão em maio de 2012 conforme fls. 170/173 e declarou que conhecia o mercado e operava por conta própria, o que corresponde a verdade, pois já fazia investimento em ações antes da [Intermediária], tendo operado com a Corretora [•] e [•]. Na verdade, a mãe da autora apenas migrou sua carteira de ações para custódia da ora ré. A carteira de ações (fls. 33) tem composição pouco conservadora, com bem aponta a ré. Além disso, as mensagens trazidas pela própria autora, extraídas do [Intermediária] Messenger demonstram, de um lado, a existência de laços sólidos de amizade e carinho entre tia e sobrinho, mas, especialmente, evidenciam a relação entre investidor e agente, com demonstração de que a [K.M.S.] entendia e operava no mercado, dando ordens a ser cumpridas pelo agente autônomo da ré. Pelas mensagens a investidora parametrava os valores de venda ou de compra de ações e quais ações pretendia negociar. Nas mensagens há uso de termos pela investidora e seu agente como "alavancagem", "a mercado", "limite operacional", "DT", "zera no leilão", "coloca venda", "coloca compra", típicos de quem conhece e opera no mercado financeiro. As mensagens, pela própria natureza da operação em bolsa, foram trocadas com espaços de tempo, por vezes, de segundos, o que torna inviável a possibilidade de que a mesma pessoa tenha enviado a mensagem como [K.M.S.] e respondido de outro dispositivo com outro login e senha como Thompson, como se verifica de fls. 190/192. Some-se a tudo isso que em algumas mensagens, o próprio agente avisa à mãe da autora de que não teriam limite operacional para fazer o que ela pretendia, o que afasta a pretensa fraude. Analisando por outro ângulo, tem-se que a mãe da autora sempre foi avisada das operações, seja pelo agente, seja pela própria B3, que enviou, como reconhecido pela autora e demonstrado no ofício judicial, todos os avisos de operações realizados, para o endereço onde residem a autora e residiu sua falecida mãe. A comunicação, feita de forma constante, acerca das operações realizadas contradizem a hipótese de fraude. A fraude se dá por meio escuso, que se procura disfarçar. No caso dos autos, as operações foram feitas às escâncaras, com ampla e irrestrita informação. Por fim, nada existe de anormal na liquidação de posições após o óbito da mãe. Como explicitado anteriormente, a carteira de ações era composta por papéis que, em razão de escândalos e da perda de atratividade no mercado (PETROBRAS, OGX, LAEP) e crise conjuntural porque passou o país, ficaram desenquadradas do perfil de risco da mãe da autora e, por isso, em cumprimento ao contrato, forma liquidadas. Em resumo, não restou demonstrada fraude ou má gestão, má atuação ou qualquer conduta que pudesse ser atribuída à ré ou preposto que estabelecesse nexo de causalidade com o prejuízo que a autora alega ter sofrido, na qualidade de herdeira. Ausentes os pressupostos da reponsabilidade civil, não há que se falar em indenização quer por danos materiais, quer por danos de natureza extrapatrimonial. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos. Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% do valor atribuído a causa. PRL." (grifos meus) (Brasil, TJ/RJ, 33ª Vara Cível da Comarca da Capital, Processo nº: 0273823-59.2016.8.19.0001, sentença disponível em <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?GEDID=0004C350A4329F50CCE6F39E428BEDC85A38C50A373B0647> . Acesso em 25.11.2021). Registro, ainda, que a sentença em questão foi confirmada em sede de apelação (Brasil, TJ/RJ, Quinta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0273823-59.2016.8.19.0001, Relator Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. em 16.07.2020, acórdão disponível em <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E9B259C898D4BAF7254CE201F59B92B4C50C512A280B&USER=> . Acesso em 25.11.2021).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

55. Por todo o exposto, considerando o contexto fático-probatório trazido aos autos, não formo convicção favorável à tese acusatória, razão pela qual voto pela absolvição de Thompson de Oliveira Schemes da acusação de **(i)** utilização de senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo de cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico, em infração à Instrução CVM nº 497/2011, art. 13, inciso VII; e **(ii)** prática de *churning*, na condição de agente autônomo de investimento contratado pela Intermediária, no que diz respeito à carteira de ações de titularidade da investidora K.M.S. no período de julho de 2012 a janeiro de 2013, em infração à Instrução CVM nº 08/1979, inciso I c/c inciso II, alínea “c”.

56. Por fim, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério Público Federal do Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício nº 190/2020/CVM/SGE, de 10.03.2020⁴⁷, para as providências que entender cabíveis no âmbito de sua competência.

É como voto.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2021.

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

⁴⁷ Docs. SEI 0953821 e 0956130.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2020/1228

(Processo Eletrônico SEI nº 19957.010573/2019-99)

Reg. Col. 2183/21

Acusado: Thompson de Oliveira Schemes

Assunto: Apurar eventual responsabilidade pela (i) prática de *churning*, em infração à Instrução CVM nº 08/1979, inciso I c/c inciso II, alínea “c”; e (ii) utilização de senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo de cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico, em infração à Instrução CVM nº 497/2011, art. 13, inciso VII.

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto: Diretora Flávia Perlingeiro

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,

1. Faço referência ao voto proferido pelo ilustre Diretor Relator Alexandre Rangel, para, respeitosamente, divergir de suas razões e conclusões no que se refere à responsabilização de Thompson de Oliveira Schemes (“Acusado”), em relação à imputação de infração à Instrução CVM nº 08, de 08.10.1979, inciso I c/c inciso II, alínea “c”, formulada em desfavor do Acusado, no âmbito deste Processo Administrativo Sancionador (“PAS”)¹, notadamente à vista do sopesamento que faço dos indícios de ocorrência da referida irregularidade neste caso.
2. O cerne deste PAS trata da apuração de responsabilidade do Acusado pela prática de negociação excessiva de valores mobiliários, no âmbito do mercado de capitais, internacionalmente conhecida como *churning*, que resta caracterizada quando realizada por pessoa que, atuando com controle sobre recursos de cliente, realiza excessivos negócios em nome desse, visando não ao melhor interesse do investidor, mas a gerar taxas e comissões em benefício próprio ou de *outrem*.
3. Segundo entendimento consolidado pelo Colegiado da CVM, para a caracterização da infração de negociação excessiva, cabe à acusação demonstrar (i) o controle que o acusado detinha sobre as operações cursadas em nome do investidor; (ii) o giro excessivo da carteira de investimentos, à luz do perfil do cliente; e (iii) a intenção de gerar receitas de corretagem ou outras comissões.
4. Por sua importância, no caso concreto, começo este voto com a análise do giro excessivo da carteira de investimentos da cliente do Acusado.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no voto do Diretor Relator ou no Relatório, conforme o caso.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

a) Giro excessivo

5. Em que pese não sejam os únicos elementos a serem aferidos para a caracterização desse tipo de infração, as apurações realizadas tanto nos mercados estrangeiros quanto no Brasil revelam a importância fundamental desempenhada pelos indicadores relativos à taxa de giro da carteira (*turnover ratio*, “TR”) e à razão custo sobre patrimônio (*cost/equity ratio*, “C/E”).

6. No presente caso, à luz da exorbitância dos indicadores apurados, sequer cabem considerações, a meu ver, a respeito de eventuais discrepâncias que poderiam conduzir a dúvidas sobre os resultados a depender da metodologia de cálculo. Ainda que tais indicadores não sejam suficientes para, por si só e independentemente de quaisquer outros aspectos do caso, impor uma condenação, entendo que, em razão de sua magnitude, não se pode deixar de considerar o peso muito significativo que representam, neste PAS, como veementes indícios de *churning*, apontando para uma *presunção relativa* quanto à sua ocorrência².

7. Com efeito, os cálculos efetuados pela BSM, a partir das operações de compra e venda de valores mobiliários realizadas em nome da investidora K.M.S., no período de julho de 2012 a janeiro de 2013, revelaram uma TR anualizada de **62,53** e uma C/E, também anualizada, de **49,19%**³, ultrapassando em muitas vezes os indicadores que o Estudo BSM identificou como sugestivos de prática de *churning*⁴.

8. Como bem apontado no voto do Diretor Relator, amparando-se em voto do ex-Diretor Gustavo Gonzalez⁵, “[a]inda que os indicadores não sejam provas incontestes da prática de *churning*, não cabe relativizá-los em demasia, uma vez que a metodologia empregada para elaboração dos indicadores partiu de circunstâncias extremas e, portanto, já consubstancia parâmetros elevados”. No caso concreto, constatou-se, em especial, uma TR anualizada **7,82 vezes maior** que o indicador sugerido pela BSM como indicativo de prática de *churning*. Por sua vez, a C/E anualizada foi **2,34 vezes superior** ao correspondente indicador da BSM.

9. A meu juízo, os Indicadores BSM apurados neste caso concreto comprovam, sob a

² Apenas a título ilustrativo, transcrevo o seguinte trecho do Ofício-Circular nº 5/2019-CVM/SMI, que remete à jurisprudência do Colegiado: “7. Os precedentes ressaltam que não se pode, à luz da legislação vigente, definir métricas puramente objetivas para a mensuração do giro excessivo. Destaca-se, nesse sentido, que o perfil do investidor é a melhor medida para aferir se o giro foi, de fato, excessivo. Nesse sentido, veja-se por exemplo o Processo Administrativo Sancionador 11/2013, julgado pelo Colegiado da CVM em 30/01/2018. 8. Não obstante, a literatura especializada e a jurisprudência, daqui e do exterior, se valem de indicadores do *churning*, dentre os quais destacam-se, por sua ampla utilização: a) Taxa de giro da carteira (*Turnover Ratio*: ‘TR’) b) Razão do custo sobre patrimônio (*Cost/Equity Ratio*: ‘C/E’) 9. Os indicadores objetivos, tais como o ‘TR’ e o ‘C/E’, fornecem apenas indícios de *churning* e nem sempre bastarão para demonstrar a prática do ilícito. Em outras palavras, o fato de a carteira ter sido movimentada em volume superior à média de mercado, ou os custos incorridos nas negociações terem consumido uma parcela expressiva do patrimônio investido, não demonstram, por si só, uma irregularidade, e, sim, uma *presunção relativa de irregularidade*.”

³ Os cálculos em questão foram encaminhados por Ofício da BSM de 11.10.2019 (Doc. SEI 0859965) e constam de planilha que também integra os autos deste PAS (Doc. SEI 0859966).

⁴ O Estudo BSM identificou que uma TR anualizada superior a 8 e uma C/E superior a 21% ao ano são indícios da referida prática fraudulenta.

⁵ Referência feita ao voto no julgamento do PAS CVM nº 11/2013, j. em 30.01.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ótica objetiva, o giro excessivo da carteira de investimentos da investidora K.M.S. e, ainda que ausentes dados mais detalhados acerca do perfil de investimento da investidora, conjugados com os demais elementos apurados, constituem indícios veementes de que o giro não foi comandado pela investidora e sim realizado com a finalidade de gerar comissões a terceiros, em detrimento dos interesses da cliente⁶.

10. Passo, então, a analisar outro elemento que integra a referida infração, que é o controle exercido pelo infrator sobre as operações executadas em nome da investidora.

b) Controle sobre as operações

11. Por um lado, como aponta o Relator Diretor em seu voto, não restaria configurada fraude na hipótese em que o próprio titular da conta tenha, de forma consciente, realizado ou autorizado as operações.

12. Entretanto, não parece plausível considerar, sob o pressuposto de que os investidores agem, via de regra, de forma racional e buscando maximizar seus rendimentos, que a investidora K.M.S. tivesse, intencionalmente, conduzido seus investimentos de modo tão excepcionalmente atípico, durante intervalo relativamente curto, realizando em dado período operações quase diárias, em seu próprio desfavor.

13. A propósito, destaco que este PAS se originou de Reclamação apresentada pela filha da investidora K.M.S., na qual são relatadas graves condutas supostamente praticadas pelo Acusado, primo-irmão da Reclamante.

14. Segundo denunciado à CVM pela Reclamante, (i) teriam sido realizadas operações com valores mobiliários sem a devida autorização da investidora K.M.S.; (ii) a investidora, no período em questão, tinha 61 anos e teria estado quase todo o tempo hospitalizada e, ainda que estivesse consciente, não tinha conhecimento suficiente para utilizar as ferramentas de comunicação por meio das quais parte das ordens teria sido transmitida nem para empregar os jargões do mercado nelas contidos; e (iii) o Acusado deteria o *login* e a senha de acesso da investidora K.M.S. à conta que mantinha perante a Intermediária e seria, na realidade, o verdadeiro responsável pelo giro excessivo de sua carteira de investimentos.

15. De certo, a existência da Reclamação, em si, não torna verdadeiros os fatos nela narrados. De todo modo, há que se pontuar que prevalece, em nosso ordenamento jurídico, a presunção de boa-fé e, ainda que não tenha havido comprovação documental em relação a alguns dos fatos narrados na Reclamação, tampouco há qualquer prova ou indício de que tais

⁶ Conforme constou do Estudo BSM, “para taxas de turnover inferiores a 2, descarta-se a possibilidade de ocorrência de churning, vez que estão em linha com o giro observado na indústria de fundos de investimento (68% dos fundos de investimento em ações giram a carteira dentro dessa faixa). Valores de turnover entre 2 e 8 são inconclusivos, não se podendo afirmar a ocorrência de churning, tampouco descartar a possibilidade. A análise da cost-equity ratio é fundamental nestas situações. Valores superiores a 8 são considerados conclusivos ou altamente prováveis da prática de churning, requerendo, entretanto, a análise do indicador de cost-equity ratio para corroborar essa conclusão”. No caso presente, a C/E apurada é superior ao dobro do valor referencial sugerido pelo Estudo BSM como indicativo da prática de churning.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

fatos seriam inverídicos. Além disso, não há como ignorar que existe compatibilidade entre (i) o que apontam os Indicadores BSM apurados em relação às negociações efetuadas em nome da investidora K.M.S.; (ii) o teor do que foi denunciado pela Reclamante; e (iii) a circunstância de que o Acusado foi beneficiado pelo alto giro da conta de investimentos da investidora, que lhe gerou um maior volume de comissões.

16. Como já asseverei em outras ocasiões, nem mesmo a revelia do Acusado afasta o ônus da acusação de comprovar a autoria e materialidade das infrações imputadas:

A revelia, contudo, em sede de PAS no âmbito da CVM, não importa em confissão quanto à matéria de fato e tampouco torna incontroversas as alegações da Acusação, que permanece com o ônus de trazer aos autos elementos suficientes de materialidade e autoria a amparar a acusação.⁷

17. Entretanto, como visto, neste caso, tem-se uma presunção relativa em desfavor do Acusado e, não tendo esse vindo aos autos apresentar quaisquer contraindícios aptos a afastá-la⁸, resta verificar se os indícios de materialidade e autoria apontados pela SMI são múltiplos, veementes e convergentes e se há nos autos elementos a fragilizá-los que não permitam uma conclusão segura acerca da responsabilidade do Acusado.

18. Releva repisar que o Acusado era sobrinho da investidora K.M.S. e era também o agente autônomo de investimentos (“AAI”) responsável pelo seu atendimento no âmbito da Intermediária, portanto, presumidamente pessoa que gozava de sua confiança, tendo atuado no período em que as operações foram realizadas, de julho de 2012 a janeiro de 2013. Como consta dos autos, a Intermediária confirmou, ainda, não haver qualquer registro formal de autorização da investidora K.M.S. quanto aos negócios realizados nos meses de setembro e outubro de 2012.

19. Quanto a esse aspecto, pelo que extraio do voto do ilustre Relator, aponta-se como elemento de dúvida a questão do efetivo controle sobre a conta da investidora pelo Acusado.

20. A respeito, a Intermediária informou que as operações em nome da investidora K.M.S. não foram realizadas via *home broker*⁹, mas as ordens eram enviadas “*via assessor*”, mediante “*confirmações por telefone não gravado (tendo em vista o grau de parentesco entre cliente e AAI), presencialmente e via chat de mensagens*”. Ou seja, as operações em nome da investidora foram executadas por intermédio do Acusado, que, no uso de suas prerrogativas como AAI, as inseriu nos sistemas da Intermediária.

21. Ocorre que, no caso das operações realizadas nos meses de setembro e outubro de 2012, período, aliás, no qual foi realizado um número maior de negócios com ativos da investidora K.M.S. do que nos demais meses do alegado cometimento das infrações, não restou comprovado o recebimento das respectivas ordens da investidora, fato esse que, em cotejo com

⁷ PAS CVM nº RJ2020/01227, de minha relatoria, j. em 21.09.2021. No mesmo sentido, havia me manifestado no julgamento dos seguintes processos administrativos sancionadores, dentre outros: PAS CVM nº 19957.009878/2019-58, j. em 02.02.2021; e PAS CVM nº RJ2017/5904, j. em 13.04.2021.

⁸ Como indica o Relatório, o Acusado não apresentou defesa neste PAS e também já não havia respondido aos questionamentos formulados pela SOI quanto ao conteúdo da Reclamação.

⁹ Vide e-mail da Intermediária constante do Processo Originário (Doc. SEI 0725647, págs. 145-146).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

a presunção relativa de ocorrência de *churning*, que decorre dos Indicadores BSM apurados, corrobora que tais operações tenham sido inseridas pelo Acusado nos sistemas da Intermediária, sem que a investidora delas tivesse conhecimento, com vistas a gerar a negociação excessiva.

22. Entendo, portanto, que a ausência de registros das operações realizadas nos meses de setembro e outubro de 2012 configura um importante indício de que tais operações não foram realmente comandadas pela investidora K.M.S., e sim exclusivamente pelo Acusado, que detinha o controle de fato sobre a conta da investidora.

23. Com efeito, em princípio, soa notadamente improvável que o Acusado tivesse recebido da investidora K.M.S. ordens, por meios informais, não gravados¹⁰, para a realização de volume excessivo de negócios, em seu próprio benefício, em detrimento dos interesses da cliente – com quem mantinha relação próxima de parentesco e, presumidamente, de maior confiança –, e, ao mesmo tempo, as tivesse transmitido, de boa-fé, aos sistemas da Intermediária, sem promover-lhes os competentes registros¹¹⁻¹².

24. Cabia, ademais, ao Acusado, na ausência de registro das ordens das operações realizadas nos meses de setembro e outubro de 2012, ter trazido aos autos deste PAS elementos que demonstrassem ter recebido instruções da investidora K.M.S. para a execução das operações em questão, ainda que por outros meios que não os previstos nas normas aplicáveis. O fato de ter sido revel não o desincumbe de tal ônus probatório.

25. Por sua vez, há, nos autos, prova documental que aponta que a investidora K.M.S. teria transmitido ordens ao Acusado, via aplicativo fornecido pela Intermediária, para a realização de operações nos meses de julho, novembro e dezembro de 2012¹³.

26. Noto, por oportuno, que tais operações representam a parte menos expressiva do total de operações realizadas¹⁴.

¹⁰ Conforme constou do Termo de Acusação: A Intermediária, “em manifestação de 13/09/16, esclareceu que o assessor (...), Thompson, era sobrinho da investidora e que, por ser um familiar íntimo, gozava de sua confiança (0725647, fls. 118 e 119)”. Nesta manifestação, a Intermediária informou, ainda, que, “..., muito embora, à época, não tenha sido possível auditar 100% das ordens emitidas pela Sra. [K.] (muitas delas, **em razão da relação familiar dos envolvidos, realizadas presencialmente, sem qualquer registro formal**), (...)” (grifos aditados).

¹¹ A Intermediária, em manifestação prévia, alegou que parte das ordens teriam sido transmitidas por telefone (não gravado) ou presencialmente, mas que teria se tratado de episódio “pontual e isolado”, motivado pela relação de confiança mantida entre o Acusado e a investidora K.M.S., que era sua tia (Doc. SEI 0725914, que consta dos autos do Processo Originário, como apontado pelo Relatório).

¹² Mesmo nesse cenário hipotético, a conduta também não se compadeceria com a observância dos deveres impostos aos AAIs. Consoante disposto no art. 10 da Instrução CVM nº 497, de 03.06.2011, à época em vigor (revogada e substituída pela Resolução CVM nº 16, de 09.02.2021), o profissional em questão deve agir com probidade, boa-fé e ética profissional, empregando no exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição, em relação aos seus clientes.

¹³ Doc. SEI 0725647, págs. 24-26.

¹⁴ Conforme descrito no voto do Relator, notas de corretagem das operações realizadas a partir da conta da investidora K.M.S. perante a Intermediária (Doc. SEI 0725647, págs. 28 a 97) revelam, no que diz respeito ao período objeto deste PAS (julho de 2012 a janeiro de 2013), que (i) houve poucas negociações, em três pregões apenas, de 02.07.2012 a 12.07.2012; (ii) não houve negociações entre 13.07.2012 e 30.08.2012; (iii) houve muitos negócios, em 30 pregões, entre 31.08.2012 e 01.11.2012; e (iv) mais uma vez, houve poucas negociações, em sete pregões, de 02.11.2012 a 27.01.2013.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

27. Mesmo quanto a essas operações, que contavam com ordens formalmente transmitidas ao Acusado, a Reclamante alega que tais ordens não teriam sido, de fato, oriundas da investidora R.M.S., pois teriam sido forjadas pelo próprio Acusado, mediante uso indevido dos dados de acesso à conta da investidora, o que, realmente, não foi comprovado.

28. A propósito, questiona-se a procedência do suposto e-mail que comprovaria o acesso do Acusado ao *login* e senha da investidora K.M.S., quanto ao que reconheço, a partir da leitura do documento juntado aos autos para fazer prova do alegado, que dele não é possível extrair informações claras de que se tratou de fato de um email ou outro tipo de mensagem eletrônica efetivamente trocada entre o Acusado e a investidora, por não conter elementos como a data e o horário do respectivo envio ou ainda os nomes e endereços de correio eletrônico de remetente, destinatários principais e em cópia. Também não consta dos autos qualquer outra comprovação do envio ou do recebimento do correio eletrônico em questão. Entretanto, mesmo sem contar com amparo no teor da referida comunicação, parece-me que não se pode ignorar que, nas circunstâncias apuradas quanto ao giro excessivo, o vínculo familiar do AAI com a investidora é forte indício de relação de confiança apto a respaldar a atuação irregular por diversos meios.

29. Chama a atenção que, ao ser intimada pela SMI a prestar esclarecimentos sobre os fatos, a Intermediária informou que (i) ao tomar contato com o conteúdo da Reclamação, iniciou procedimento interno de auditoria de ordens, para identificar a integralidade dos registros das operações executadas em nome da investidora K.M.S.; e (ii) na auditoria em questão, a Intermediária também identificou possível compartilhamento de senhas entre o Acusado e a investidora K.M.S., com base no que seria um correio eletrônico trocado entre eles, tendo apresentado, para instruir suas alegações, o mesmo suposto correio eletrônico que, segundo a Reclamação, comprovaria o referido compartilhamento¹⁵.

30. Então, se por um lado, o suposto e-mail, por seus atributos intrínsecos, não pode ser considerado como prova documental de que houve compartilhamento do *login* e senha da conta da investidora K.M.S. com o Acusado, entendo, de outra parte, que o fato de a Intermediária estar de posse do mesmo documento fornecido pela Reclamante e tê-lo igualmente apresentado à CVM como evidência do possível compartilhamento de dados de acesso à conta seria um indício de que tal fato teria ocorrido e, conseqüentemente, sugeriria que o Acusado possa dele ter-se valido para simular o envio de ordens, pela investidora, a si próprio, para a realização de operações em nome dela, com o objetivo de elevar as comissões percebidas¹⁶.

31. Nesse contexto, cabe reconhecer que, em que pese a Reclamante ter alegado que a investidora, em razão de sua idade e suposto perfil, não teria conhecimento de expressões do jargão de mercado de capitais, empregadas nas mensagens em seu nome transmitidas pelo

¹⁵ v., respectivamente, o Doc. SEI 0725914, constante do Processo Originário, p. 41 e o Doc. SEI 0725647, p. 22.

¹⁶ Em que pese a ausência de dados relativos a data e horário de envio, bem como quanto ao remetente e destinatário da mensagem, consta na parte inferior do documento uma referência de que teria sido extraído do endereço <http://36ohk6dgmmedln-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36oh...>, em 13.06.2012, data que antecede ao início da prática das condutas que são imputadas ao Acusado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

aplicativo da Intermediária, não há, nos autos, provas ou indícios de que tais mensagens não pudessem ter sido de fato transmitidas pela própria investidora nem de que tivessem sido forjadas pelo Acusado, em seu nome.

32. Também concordo com o Diretor Relator que poderiam ter sido apresentados, sem grandes dificuldades, documentos ou outros meios de prova (atestados, laudos ou prontuários médicos de qualquer natureza) que pudessem corroborar o quanto dito pela Reclamante no tocante ao estado de saúde da investidora e sua alegada hospitalização em dado período e impossibilidade de comunicação nesse período, o que não ocorreu.

33. Porém, a meu juízo, a ausência das referidas comprovações não é suficiente para afastar a força do conjunto dos demais indícios reunidos (mesmo desconsiderando-se o teor do suposto e-mail), sendo totalmente improvável que a própria investidora tenha efetivamente pretendido realizar o referido giro excessivo da sua carteira de investimentos. Nesse sentido, observo que, no mínimo, caso não fosse o Acusado o responsável pelo giro excessivo na carteira da sua tia, que ele a tivesse alertado dos prejuízos que o giro lhe estava causando e não haveria qualquer explicação racional para que, uma vez alertada por seu sobrinho, essa não continuasse a fazê-lo em tantas outras operações, como ocorreu.

34. Mais uma vez, portanto, os indícios até aqui convergem no sentido de evidenciar a prática do ilícito pelo Acusado.

35. Em suma, como referido pelo Relator, o controle sobre a conta do cliente é também elemento necessário para a caracterização do *churning*. A princípio, o giro excessivo não seria por si só suficiente para configurar a prática fraudulenta, pois pode se traduzir em situação em que o próprio titular da conta é que tenha realizado as operações de forma consciente¹⁷. Tal controle da conta pode se dar de forma lícita ou ilícita, mas, de todo modo, isso não quer dizer que a sua comprovação também não se possa extrair do conjunto de indícios sopesados, em especial, neste caso, o vínculo familiar, a atuação no mercado por meio do Acusado e a ausência de registro de ordens para a maioria das operações realizadas, que apontam para a confiança da referida investidora na *expertise* do sobrinho e para um abuso dessa confiança, por parte deste.

36. Por fim, cabe analisar o elemento subjetivo (*dolo*), que é igualmente exigido pelo tipo administrativo.

c) Elemento subjetivo

37. Para além dos meios já consolidados para aferição dos elementos objetivos do tipo consubstanciados no giro excessivo da carteira de valores mobiliários de investidor e no controle sobre a conta de investimentos, os precedentes da CVM reconhecem que o elemento subjetivo da referida infração também pode ser demonstrado a partir de prova indiciária, desde que a acusação seja suportada por uma pluralidade de indícios sólidos e convergentes, que não

¹⁷ v. PAS SP2014/0465, Diretor Relator Gustavo Machado Gonzalez, j. em 06.11.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

sejam invalidados por contraindícios¹⁸.

38. Com efeito, dificilmente há prova documental da intenção do agente. Desse modo, o elemento subjetivo é normalmente constatado a partir dos demais elementos já citados.

39. No caso, os Indicadores BSM mostram que os negócios não apresentam um racional econômico que os sustente, mas foram realizados com o objetivo de proporcionar despesas com comissões ao intermediário. Por sua vez, a meu ver, restou demonstrado que o Acusado detinha o controle de fato da conta da investidora K.M.S. Daí que se conclui que o Acusado, ao realizar as operações, foi movido pelo intuito de majorar as comissões devidas pela investidora.

40. Ainda em linha com precedentes do Colegiado¹⁹, também considero que a intenção de auferir vantagem financeira indevida se infere do fato de o Acusado ter obtido vantagem financeira a partir da excessividade de negócios que realizou em nome da investidora K.M.S., tendo em vista a parcela percebida sobre as taxas de corretagem, as quais representaram grande parte dos custos de transação suportados pela referida cliente.

41. Por conseguinte, divirjo do entendimento do Diretor Relator, por entender que neste caso há indícios robustos e convergentes que apontam não só para o giro excessivo da carteira da investidora K.M.S., mas também para o fato de que o Acusado tinha o controle de fato sobre a conta da investidora, ao menos durante parte do período indigitado, e que se utilizou intencionalmente de tal controle para realizar as operações de modo a gerar comissões em seu benefício e da Intermediária, em detrimento dos interesses da investidora.

42. Pelo exposto, com base na prova indiciária trazida aos autos, formo convicção pela condenação do Acusado no que tange à prática de *churning* que lhe foi imputada.

43. Por fim, gostaria de acrescentar um registro com relação ao reconhecimento da consunção, apontada pelo Relator em seu voto, e reconhecida em precedentes do Colegiado. Segundo se depreende da própria tese acusatória, a alegada utilização, pelo Acusado, de *login* e senha da investidora K.M.S. teria servido tão somente como meio para a prática do *churning*.

44. Nesse cenário, concordo que a condenação do Acusado pela violação ao inciso I c/c inciso II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 08/1979, não poderia, ao mesmo tempo, configurar violação ao art. 13, inciso VII, da Instrução CVM nº 497/2011, eis que tal irregularidade, no caso, se traduziria em infração-meio para a prática da infração principal, razão pela qual acompanho a conclusão do voto do Diretor Relator no que tange à essa segunda imputação.

45. Ressalvo, contudo, que isso nem sempre ocorrerá no contexto de acusação de prática de negociação excessiva e de concomitante uso de senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico. Caso, por

¹⁸ Exemplificativamente: “Vale ressaltar que tanto o descasamento entre o giro da carteira e o perfil de cliente quanto ao elemento subjetivo podem ser demonstrados a partir de provas indiciárias, desde que a acusação seja suportada por uma pluralidade de indícios sólidos e convergentes, que não sejam invalidados por contraindícios.” (PAS CVM nº 11/2013, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 30.01.2018).

¹⁹ Vide PAS CVM nº RJ2015/6143, j. em 24.04.2018; PAS CVM nº 22/2013, j. em 18.09.2018; e PAS CVM nº CVM Nº 04/2016, j. em 15.12.2020, todos de relatoria do ex-Diretor Gustavo Machado Gonzalez.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

exemplo, estivéssemos diante da alegação de utilização, pelo Acusado, dos dados de acesso à conta da investidora K.M.S. para outros fins que não exclusivamente no contexto da prática da negociação excessiva, tal conduta, caso restasse comprovada, configuraria infração autônoma, passível de sanção administrativa, independentemente, portanto, da conclusão a que o Colegiado chegasse sobre a acusação da prática de *churning* propriamente dita.

46. Em relação à fixação da penalidade a ser cominada ao Acusado, assinalo que a prática de *churning* é considerada grave para os fins previstos no §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976, nos termos do item III da Instrução CVM nº 08/1979. De fato, a mencionada conduta é especialmente danosa à credibilidade do mercado de valores mobiliários, uma vez que é praticada em detrimento da confiança depositada por clientes nos profissionais que atuam no mercado. Por outro lado, contam a favor do Acusado os seus bons antecedentes. Considero, ainda, que a conduta objeto deste PAS se refere a uma única investidora em curto período.

47. Pelo exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385/1976 e, ainda, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto:

- a. pela condenação de Thompson de Oliveira Schemes à multa pecuniária no valor de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), prática de *churning*, em infração à Instrução CVM nº 08/1979, inciso I c/c inciso II, alínea “c”; e
- b. por sua absolvição da acusação de utilização de senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo de cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico, em infração à Instrução CVM nº 497/2011, art. 13, inciso VII.

É como voto.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2021.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro

Diretora